

L'organisation administrative. Benessiano

Si livre : institution administrative mais pas nécessaire

Examen : QCM

Cours :

Structuration de la matière

Année en 2 parties :

- 1^e Les institutions administratives (4 séances)
- 2^e rapports entre institutions administratives/administration et les religions (5 séances)

Partie 1 : Les institutions administratives

4 paragraphes :

- I- **Administration étatique et déconcentrée**
- II- **Décentralisation**
- III- **Les autres institutions administratives/ Les autres institutions**
- IV- **Les autorités administratives indépendantes**

INTRODUCTION : Comprendre ce qu'est un état, une administration et établir un rapport entre l'état, l'Administration (majuscule si on parle de l'Administration française) et pouvoir politique. L'Administration c'est synonyme **d'institution administrative**. Il n'y a pas une Administration française mais des administrations françaises. Les administrations ont un lien avec l'histoire. Comprendre à comment on est arrivé à des administrations et pas Une administration. Quand on parle **d'Administration**, il faut penser à la **diversité, aux services publics**. La fac est une enceinte administrative et le prof un agent administratif ; ce n'est pas une administration de l'état, elle est un peu spéciale (voir IV) comme les hôpitaux. Il n'y a pas que les administrations qui font du service public (ex : bus). On doit envisager l'administration comme étant au service du pouvoir politique. Les administrations constituent le bras armé du politique pour qu'il réalise ses performances. Etat, institutions, pouvoir, la boucle est bouclée. Dans chaque état, il y a **3 séries d'institutions** publiques chargées de remplir un certain nombre de missions chargées de diriger, de prévoir, prestations, garantir la sécurité... **1ere** série d'institutions : **Institutions politiques**= pouvoir politique, elles doivent prendre les grandes décisions, diriger, faire de la diplomatie, elle dirige l'état, au niveau international et interne (président...) => droit constitutionnel. **2^e série** d'institutions : elles sont au service du pouvoir politique et des administrés, au **service du pouvoir**. Ex : pouvoir politique (Marcon) décide un pass sanitaire -> institutions administratives sont chargées d'appliquer ces textes en adoptant d'autres textes. En droit il y a une **hiérarchie des normes** ; le droit français (= ensembles de normes) hiérarchise les normes juridiques en fonctions de leur objet etc., plus on descend, plus on arrive à des normes choisies par l'administration. Quand on parle de

règlement on pense à l'institution administrative. Les institutions administratives mettent en œuvre, servent etc. = **rédiger des textes** pour elles. L'administration est chargée de rédiger des normes, des textes juridiques pour en appliquer d'autres. Une loi à besoins de ça pour être mis en œuvre. Arrêtés, décrets, circulaire = administration toujours ; ils sont réalisés pour appliquer les lois : nécessaire. Les détails sont dans les règlements pris par les administrations. La deuxième mission de **l'administration : on exécute**. Si on devait résumer ; l'administration est surtout au service du pouvoir exécutif (= gouvernement, président, institutions politiques) **l'administration c'est l'ensemble des institutions qui exécute à l'aide de ces organes ce que veulent les institutions politiques**. Le préfet est une institution administrative déconcentrée qui travaille sous la direction du pouvoir exécutif qui fait partie du pouvoir politique. Le pouvoir exécutif en France ne fait pas qu'exécuter ; il dirige, il prévoit... Les grandes décisions sont réalisées par le pouvoir politique et exécutif, le parlement va transcrire dans des lois ce qu'ils veulent et l'administratif va mettre en œuvre par des normes, règlements, arrêtés, décrets... Il y a une autre mission importante pour l'administration, elle est chargée aussi de **délivrer des prestations de services publics** qui vont avec les textes qu'elle **rédige** (<- première mission) : c'est faire respecter tout. Administration = 2 séries d'opérations : 1^e activités juridiques : on rédige et activités matérielles : 2^e on fait appliquer (ex : police). 3^e institutions : institutions juridictionnelles= c'est la justice.

3séries d'institutions : 1. politique = décide / 2. administrative : met en œuvre / 3. juridictionnelle : corrige

Les 4 paragraphes

- Lorsqu'on entend « Etat + déconcentré » il faut penser au pouvoir exécutif, penser à l'état en tant que personne
- La décentralisation= on change de personne, c'est plus l'état mais notamment les communes
- Les autres = on parlera des établissements publics (ex : université), pas l'état, la commune ou la région ; encore une autre personne. Ex les administrations universitaires choisissent du classement Parcoursup même si c'est l'état qui l'a créé.
- Les autorités administratives indépendantes : dans un certain nombre d'états providence= créations pour rédiger des textes toutes en les rendant indépendante (oxymore car administration ne peut pas être indépendante...) Exemple : l'audio visuelle : administration mais indépendante (voir tv)

CHAPITRE I : L'ADMINISTRATION ETATIQUE ET DECONCENTREE

A- La construction de l'Etat

B- L'Etat

C- L'administration centrale

D- La déconcentration

Introduction du 1^e paragraphe : Quand on parle de l'administration de l'état on parle de différentes catégories d'administrations. On peut distinguer ces administrations en fonction de leur mission, mais aussi de leur situation territoriale (certaines sont centralisées (la plupart sont à Paris : Ministère mais il peut y en avoir ailleurs ex Nantes, celles des casiers judiciaires/celles des magistrats à Bordeaux), d'autres sont déconcentrée. Quand une administration centrale est unique est n'est pas à Paris, c'est la délocalisation. Si on en place de partout dans le territoire c'est la décentralisation. On peut donc distinguer les **administrations étatiques** en fonction de leur mission ; il y a **3 grandes séries de missions**. La 1^{ere} = **prévision, direction et impulsion** (c'est le sommet de l'administration qui prend les principales décisions (ex : ministère). 2^e série de mission = **institutions de consultation** (on est encore dans l'état) elle se charge de donner leur avis (ex : conseil d'état : institution juridictionnelles et administratives de consultations, chargée de contrôler d'autres administrations). 3^e série de mission = **contrôle** (ex : les bavures policières = enquête interne/ inspection (normalement pas étudiée cette année...))

A- La construction de l'état

Très compliqué de donner une date notamment au regard de la définition de l'état car il y a plusieurs types de définitions. Si on devait néanmoins donner une date : date de **naissance de l'état français** au point de vue juridique : **1789**, c'est-à-dire la révolution mais surtout le moment à partir duquel on va avoir un **Etat nation unitaire** pour la France. Qui est un état qui va se caractériser par la volonté de construire une nation ; une **nation c'est un ensemble d'individu qui d'une certaine façon ont envie de vivre ensemble parce qu'il croit en un certain nombre de valeurs**. L'idée est de passer d'une société de classe à une société soumise aux mêmes règles. Il y avait avant, une telle diversité qu'on ne pouvait parler d'une **homogénéité nationale**. L'état nation est un état qui se définit par cette homogénéité : langue, histoire, mêmes règles... Nous sommes encore un **état unitaire** car il y a un principe **d'indivisibilité de la souveraineté** : il y a un seul parlement, un seul gouvernement, un seul chef d'état (lorsqu'une loi est adoptée par 1 seul parlement, elle est appliquée). Même si cette nation unitaire c'est créée en 1789, on a eu une série de rois (centralisateur), qui vont avoir pour ambition au nom de leur pouvoir, d'avoir un état fort et capable d'imposer leur volonté et mettent en place des structures politiques et administratives chargées de centraliser leur pouvoir. On va donc avoir en France, sous l'ancien régime, les premières grandes institutions administratives chargées de centraliser le pouvoir (ex : le conseil du roi, la constitution de l'ancêtre de la cour des comptes (qui rend des avis sur l'aspect financier de l'état) toutes ces institutions sont créées avant la Révolution française. Elles servent à consolider le pouvoir du

roi. Après la révolution, d'autres raisons vont justifier la création d'un pouvoir politique et d'une série d'administration chargée de prendre des décisions qui s'appliqueraient sur tout le territoire, c'est notamment la construction de l'état providence. **L'état providence**, au point de vue juriste, c'est **l'état qui va prendre en charge au niveau administratif d'un certains nombres de responsabilités**. L'état se construit autour d'une figure centrale pour affermir le pouvoir du roi et plus tard ce n'est pas pour le pouvoir du chef mais pour servir aux besoins des administrés. Autour de cette figure qui est l'état gendarme qui est l'état dont la mission principale est de garantir la sécurité à l'intérieur et l'extérieur mais aussi au niveau régalien. Avant cela, les règles et impôts n'étaient pas les mêmes. Des corps intermédiaires assumaient des fonctions qui sont après chargées par l'état (ex : église catholique...). L'état se concentrait sur ces missions **régaliennes**. Après la révolution, l'état assume de tout ce qu'il n'assumait pas avant, c'est l'état providence. L'état a été obligés de déléguer certaines de ces missions car c'était trop important (déléguer aux II/III/IV + il a laissé à des entreprises privées s'en charger). Il faut avoir en tête l'idée selon laquelle, l'administratif ne relève pas toujours de l'administration = l'administratif en tant que mission ne relève pas toujours de l'administration (personne publique). L'administration fait de l'administratif. On peut parler de privatisation lorsqu'on procure à une entreprise privée de faire de l'administratif. On peut conclure en disant : quelle période sommes-nous en train de vivre ? double mouvement : on assiste en termes de missions administratives par l'administrations : plus grande prise en charge et présence de l'état mais aussi mise en recul de l'état. Exemple : depuis **1990** il y a eu une **ouverture à la concurrence** (ex électricité/transport...) des **services**. L'état se désengage un peu. En privatisation on peut penser (depuis l'état d'urgence) des entreprises de sécurité privée : on privatise un peu la sécurité ; en revanche l'état providence ne se désengage pas tant que ça (ex : manifestation...).

B- L'Etat

L'état en tant que tel : comment peut-on définir ce qu'est l'Etat ? Définition d'un juriste : **l'Etat c'est une personne morale ayant une nature particulière**. Le mot personne peut être défini de 2 façons : façon ordinaire = un humain/ en droit, une personne peut désigner plusieurs choses : c'est surtout une personne juridique c'est-à-dire tout individu ou toutes entités dotées de la personnalité juridique. La **personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droit et d'obligation**. L'université est une personnalité juridique qui a des droits, peut signer un contrat, on peut l'attaquer... Il agit à travers ses institutions politiques et administratives, un peu à l'image des sociétés. Notre état s'incarne dans des institutions politiques qui s'incarnent dans des personnes. On a deux catégories de personnes dans l'Etat : les **personnes physiques** (les humains) et les **personnes morales** (l'état/association/commune d'Aix... regroupement de personnes physiques). Il y a 2 types de personnes morales : les personnes **morales de droit public** et les personnes morales de **droit privé**. Le droit est divisé en 2 catégories : **droit privé = concerne entre les particuliers/ droit public = régit les rapports entre les personnes publiques et les personnes privées** (toutes les personnes physiques sont privées). On distingue aussi les personnes morales privées et les personnes morales public (de droit public). L'état est une personne morale de droit public car il agit dans le cas de l'intérêt

général. Une autre personne morale de droit public : les collectivités territoriales (qui dit décentralisation) et donc à un statut moral de droit public. Les établissements publics sont des personnes morales de droit public. Les personnes morales de droit privé sont la société de transport par exemple, les associations, elles sont globalement soumises aux mêmes règles que les personnes physiques.

L'état est une personne morale d'une nature particulière ; la **personne morale étatique** est dotée de **3 caractéristiques**/caractères : la 1ère= elle est **une personne souveraine**/doté de la souveraineté = dans l'Histoire, pour nous faire accepter l'idée d'un pouvoir au-dessus de notre tête, il fallait une idée : au départ= dirigée par quelque chose venant du sacré/croyance ; après (aujourd'hui) on a l'impression qu'on aura un minimum de sécurité et de prestations de services publics assez satisfaisante. L'Etat est le souverain, le patron, le seul capable de nous imposer l'ensemble de ses règles et de manières unilatérales. Cette souveraineté dont l'état est titulaire, lui permet d'imposer ses règles et de se présenter en égal dans la communauté internationale. Néanmoins, c'est vrai mais il faut relativiser, les états ne sont pas entièrement égaux dans la communauté nationale : c'est un principe plutôt formel. Dans le cadre de la mondialisation, l'Etat français a transféré une partie de sa souveraineté (ex : à l'union européenne), a concédé des parcelles.

L'état se caractérise également par son **universalité**. Le principe d'universalité signifie que l'autorité de l'Etat, **concerne l'intégralité de son territoire et de sa population**, on dit de l'état qu'il **possède la compétence de la compétence**. Il y a une universalité territoriale, personnelle et l'état décide de ce qu'il a à faire et détermine ses compétences, sous réserve des compétences transmises.

Enfin, l'Etat se caractérise par son caractère **unitaire** (voir explication de l'Etat unitaire plus haut). Il doit y avoir une seule série d'institutions politiques chargées de créer les droits, les faire, les écrire et faire appliquer. L'état unitaire c'est un endroit où les règles sont effectuées de la même manière dans tout le territoire

C- L'administration centrale ou centralisée

L'administration centrale se situe souvent à **Paris**. Pour remplir ses missions, l'Etat a besoin d'un appareil administratif organisé et hiérarchisé. Il y a d'une part le chef de l'Etat et d'autre part le gouvernement pour cette administration centrale. La présidence de la République et le gouvernement sont à la fois des institutions politiques (droit constitutionnel) mais aussi des institutions administratives ; elles ont des **fonctions politiques** (ex : le chef de l'Etat agit sur la scène internationale, prend la décision de dissoudre l'assemblée) mais aussi **administratives**. Le chef de l'Etat, dans le monde, peut être un monarque (roi) ou un président, selon les pays. Dans un certain nombre de pays qui sont dans une République, c'est surtout un rôle symbolique (exemple : Allemagne, Italie). Dans l'Union européenne il n'y a qu'en France que le président possède des prérogatives effectives. Cela est lié à notre histoire et aux conditions de la mise en place de la Ve République. Le **chef devait incarner l'Etat**. Faire du chef de l'état une institution importante passe par un renforcement de pouvoirs politiques et de ses fonctions administratives. Par exemple, dans l'**article 13 de la constitution actuelle** : le chef

de l'Etat d'une part dispose d'un important pouvoir de nomination et d'autre part dispose d'un pouvoir réglementaire. Le président de la République a un certain nombre d'emplois civils, militaires, voir juridictionnels : le président nomme des ambassadeurs, préfet, magistrat etc... et avec ce pouvoir, il est en mesure de s'assurer de la loyauté des personnes qu'il va nommer. En effet, lorsqu'un nouveau président est élu, dans certains grands emplois au niveau civil, il y a un grand changement ; c'est également le cas au niveau militaire. On peut se référer aux Etats-Unis, des individus vont passer leurs premières semaines de leur mandat à donner des emplois et nommer des personnes notamment dans le milieu juridictionnel. Ils nécessitent une organisation capable de décider avec eux et participer au pouvoir parlementaire. La fonction de nomination fait du président de la République une institution administrative. Le **pouvoir réglementaire** c'est la **capacité juridique consistant à adopter des normes générales d'application**, le plus souvent des lois. Il faut appréhender le Droit en fonction de couche normative cf. la pyramide des normes : les plus basses sont les normes réglementaires et la présidence de la république fait partie de ce pouvoir de les adopter. Il y a donc bien des fonctions administratives. A cet égard, le **président de la République contresigne** les décrets d'application des lois. Parmi les actes administratifs, les plus importants sont les décrets, l'un des objets des décrets et de prévoir l'application des lois. La fonction de nomination est une fonction administrative qui s'exerce via des actes administratifs. Pour exercer ces fonctions administratives, la présidence est composée d'environ 1000 personnes qui aident le chef de l'Etat, le personnage central est le secrétaire général de la présidence de la république/Elysée. Il est chargé d'énormément de fonction avec pour principale la coordination avec le gouvernement notamment dans la préparation des projets de lois. D'autre part, le gouvernement, c'est le véritable sommet de l'administration française « ***l'appareil administratif de l'Etat se trouve placer sous le gouvernement*** ». **Article 20 de la constitution** : « ***Le gouvernement dispose de l'administration.*** ». Attention, le gouvernement dispose de l'administration de l'Etat, pas de toutes les administrations. Le gouvernement a des responsabilités politiques comme celles de l'Etat ; par exemple, tout ce qui renvoie à la procédure d'adoption des lois notamment. Le gouvernement participe au processus de fabrication des lois. Le gouvernement, en tant qu'organe collégiale, c'est-à-dire un organe composé de plusieurs individus, est composé de membres qui disposent pour la plupart d'une administration et exerce un pouvoir hiérarchique, par exemple : le fait d'organiser ses services d'une certaine façon permet à ses ministres d'organiser son pouvoir réglementaire. Également, les ministres rédigent des circulaires (normes sur la façon d'appliquer un texte), ils peuvent être amenés à signer des décrets d'applications des lois qu'ils sont chargés de faire exécuter. **Le contresigne c'est lorsqu'une autorité détermine l'autorité qui est chargée responsable de son application, il formalise le fait que c'est le gouvernement qui est responsable de l'application de la loi.**

Qui dit Premier ministre, dit secrétaire général du gouvernement (bras droit du 1^{er} ministre). Ce dernier n'existe pas dans tous les pays (exemple : aux Etats-Unis). Dans l'Union Européenne, nous sommes dans ce que nous appelons un régime parlementaire (peut être monarchie ou république). Le **régime parlementaire** c'est un régime politique qui notamment se caractérise par un **pouvoir exécutif bicéphale**. C'est un régime dans lequel il y a un chef d'Etat et un chef du gouvernement ; il y a **deux têtes en haut du régime**. Le **chef du**

gouvernement et le premier ministre y ont l'autorité sur l'ensemble des ministres, ils assurent la coordination interministérielle au travers du secrétariat général du gouvernement. La fonction de premier ministre est assez récente, en effet, sous la IIIe République il y avait un président du Conseil qui avait différent rôle et, il était ministre et été également chargé en plus d'effectuer une coordination. Vers **1935**, le président du conseil ne se charge plus que de la coordination et la **présidence est transféré à Matignon**. C'est alors la fonction du Premier Ministre qu'on connaît. Quelles sont les différentes **fonctions** qui font du **Premier ministre** une autorité administratives aujourd'hui ? Par exemple, la **préparation du conseil des ministres**, des **projets de loi**, des ordonnances, l'exercice du pouvoir réglementaire, de nomination, la **coordination** entre tous les ministres, l'élaboration du budget de l'Etat : préparation (qui passe d'une coordination des ministères dépensiers (ont besoins de budget) et le ministre de l'Économie) etc...

L'administration centralisée est divisée en ministères qui sont dirigés par le ministre par l'aide de son cabinet. Les ministres sont nommés par le président de la République sur proposition du premier ministre. Sociologiquement, si on regarde l'évolution des ministères en France, il y a une réduction du nombre de ministres au sein du gouvernement, il y a une diminution du nombre de membres du gouvernement et donc de ministères, il y a également eu une modernisation de leur appellation : ministre des Armée-> ministre de la Défense. La composition varie en fonction du gouvernement et des priorités du président. Il y a eu une féminisation du gouvernement et une ouverture à la société civile, c'est-à-dire des individus qui n'ont pas fait de la politique leur métier. La structuration de l'administration centrale en ministères se retrouve dans la plupart des régimes parlementaires. Selon le statut du membre du gouvernement les responsabilités ne sont pas les mêmes. Il existe quand même une hiérarchie d'un gouvernement, tous n'ont pas les mêmes responsabilités et ne disposent pas forcément d'autonomie, et certains ne disposent pas d'autorité administrative.

D- La déconcentration ou l'administration déconcentrée de l'Etat, l'administration territoriale de l'Etat, les services déconcentrés

Lorsque l'on parle de déconcentration, il n'est pas encore en rapport avec les collectivités territoriales.

La déconcentration est un phénomène qui a toujours existé en France et se retrouve dans la plupart des pays. Les autorités déconcentrées sont sous l'autorité du gouvernement. La **déconcentration** se compose **d'administrations qui ne sont pas autonomes**. Il y a deux citations qui permettent d'illustrer ce qu'est la déconcentration : **Louis Napoléon Bonaparte** « *On peut gouverner de loin mais, on administre bien, que de près* » ; on prend les décisions à Paris et on les met en œuvre au niveau local également **Odilon Barrot** « *avec la déconcentration c'est toujours le même marteau qui frappe ; seulement on en a raccourci le manche* » C'est toujours l'Etat qui frappe mais le manche est manié depuis le niveau local. Quand on parle de **déconcentration**, on parle de **représentants de l'Etat au niveau local**.

La **déconcentration** c'est un **processus par lequel, l'Etat découpe son territoire en circonscriptions administratives** (il ne s'agit pas de collectivités territoriales mais des

communes par exemples) **afin d'y nommer des représentants nommés** (qui ne sont pas des élus mais les maires par exemple) **chargés d'appliquer au niveau local des décisions prises par le pouvoir centralisé, par le gouvernement**. Ceux sont des autorités dépourvues d'autonomie et qui n'ont pas la personnalité juridique, contrairement à la collectivité territoriale. Les circonscriptions administratives dérivent de l'Etat qui lui a la personnalité juridique. Le découpage de l'Etat est effectué par le pouvoir central, soit par des lois, soit par des décrets. Il y a eu énormément de découpage durant les dernières années, le découpage s'est réalisé progressivement mais il a été initié au lendemain de la Révolution. Les premiers découpages concernent les communes puis les départements. Il y a une visée d'homogénéité du découpage. Encore aujourd'hui, les maires peuvent être envisagés comme des représentants de l'Etat mais pas pour toutes les politiques qui sont appliquées. Le maire assume ses missions (ex : mariage) avec ses services (communes, municipaux etc...) mais au nom de l'Etat. Au départ, les maires étaient nommés, maintenant ils sont élus car, tout en restant des représentants de l'Etat, ils sont aussi les représentants de leur commune en tant que la commune est aussi une collectivité territoriale. Une **commune** est une **circonscription administrative de l'Etat** avec un représentant de l'Etat (maire élu) mais, les communes sont aussi aujourd'hui des **collectivités territoriales** avec une personnalité juridique.

Le préfet est et restera représentant de l'Etat, il n'a qu'une casquette. Alors que le **maire** en a deux : **représentant de l'Etat et des collectivités**.

Le préfet, selon **la loi du 28 pluviôse de l'an 8**, il assure en France la représentation de l'Etat. **« Il faut toujours en revenir à ce point : le gouvernement dans les départements c'est le préfet » Stendhal**. Le préfet est l'incarnation de l'unité de l'autorité de l'Etat. Il veille à ce que les lois votées par le parlement soient bien appliquées. **L'article 72 de la Constitution** dispose que **« dans les collectivités territoriales, le représentant de l'état (= préfet), représentant de chacun des membres du gouvernements, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois »**. Une mission importante du **préfet** est ce qu'on appelle en droit le **maintien de l'ordre public** puisqu'il veille à ce que les activités humaines dans les départements ne causent pas de troubles dans l'ordre public à travers des **arrêtés préfectoraux**, étant des mesures dites de **police administrative**. Au préfet de département c'est ajouté en 1964, le préfet de région. Ils constituent une nouvelle subdivision territoriale déconcentrées. Les **trois circonscriptions administratives** de bases sont les **communes** (maire), les **départements** (préfet) et les **régions** (préfet) mais, il y en a d'autre comme les académies (recteurs). Les préfets sont nommés en conseil des ministres et on dit d'eux qu'ils occupent des emplois à la discrétion du gouvernement. Le premier ministre et le président de la République, c'est-à-dire le pouvoir administratif peut nommer et dénommer qui ils veulent.

Il y a eu une réforme sous François Hollande car on a redécoupé la carte des régions, il n'y a plus que 13 régions métropolitaines. Les départements sont eux-mêmes divisés en arrondissements au sens de la déconcentration avec pour chacun une sous-préfecture. Les Agence Régionale de la Santé sont des autorités déconcentrées.

II- La décentralisation

Il y a 2 définitions de la décentralisation et durant tout le paragraphe, sera envisagée la décentralisation territoriale. Il faut donc penser aux communes, aux régions et aux départements. Il s'agit de parler ici de transferts de compétences vers les collectivités territoriales qui ont 2 statuts. Elles sont administrées par des conseils élus (et pas nommés). La **décentralisation** est un processus à la fois ancien et récent. Dès la **fin du XIV** il y a eu des réformes. Malgré cela, la **décentralisation** telle qu'on la connaît aujourd'hui est beaucoup plus récente et date de **1982** avec des réformes assez régulièrement. La décentralisation ne remet pas en cause le caractère unitaire de l'Etat. On dit de la France qu'elle est un Etat unitaire décentralisé, ceux ne sont pas des termes opposés. Les lois restent les mêmes sur l'intégralité du territoire mais ce qui a changé est la façon dont on va exécuter les lois. Dans le cas de la décentralisation, les collectivités auront une marge d'autonomie. La décentralisation se concrétise à travers la reconnaissance du pouvoir parlementaire local. Il y a en effet des règlements qui s'applique dans le territoire des collectivités. La décentralisation s'est effectuée du fait du libéralisme et d'autre part de l'état de providence. Le libéralisme signifie que si la décentralisation commence sous la IIIe république ce n'est pas par hasard, le parlement adopte à la période de lois libérales (liberté presse...), en même temps que l'Etat reconnaît des libertés aux individus, il les reconnaît aux territoires, aux collectivités. La deuxième logique de l'aspect libéral est la logique état providence, il s'agit d'une période à partir de laquelle l'état va se mettre à agir et ne sera pas en mesure de s'occuper de tous les services publics, il va « délaissier » certaines charges aux territoires : aux collectivités territoriales.

A. Le cadre de la décentralisation

1. La définition et les notions

Une **collectivité territoriale** c'est un territoire doté de la personnalité juridique. C'est une personne morale. Le fait que ce soit une personne morale la distingue d'une circonscription administrative. On a sur un même territoire 2 statuts. On a deux politiques différentes. Tout ce qui concerne la gestion du patrimoine et des collèges c'est au niveau territorial. Parfois pour une politique dans un domaine proche, on a 2 politiques différentes et 2 niveaux différents (éducation, enseignement il y a les professeurs donc le rectorat donc l'Etat et l'Etablissement donc les collectivités). Avant même la décentralisation de manière moderne de 1982, on a eu la reconnaissance de la personnalité juridique notamment aux communes (1837) et aux départements (1871). Une **collectivité est un territoire qui s'administre par des conseils élus**. Non seulement elle possède la personnalité juridique mais aussi elle s'administre via des conseils élus. Le système des élections au niveau local a été généralisée en 1982. C'est à partir de cette date que tous les 6 ans ont lieu les différentes élections (pas nécessairement en même temps depuis peu). Il n'y a pas de décentralisation sans élections.

Pendant longtemps, il y a eu une confusion entre collectivités territoriales au ressort limité et établissements publics. Une collectivité avait déjà un ressort limité alors qu'un établissement public avait du ressort sur l'ensemble du territoire. Un **établissement public c'est une personne mais qui gère qu'une activité**. La différence que l'on faisait était ce champ géographique. Lorsque l'on est en présence d'un établissement public, on parle aussi de décentralisation.

La deuxième décentralisation est la **décentralisation fonctionnelle**. C'est un **transfert d'un seul service à un établissement public qui a une vocation générale** (ex : la Sncf), contrairement à la décentralisation territoriale où il transfert des compétences.

Les **collectivités territoriales** dès le début de leur histoire jusqu'en **2015**, bénéficiaient d'une compétence générale ; elles avaient la **clause de compétences générales**. Aujourd'hui, seules les communes disposent de cette clause. Avant, c'était le cas pour les communes, les départements et les régions. L'Etat, par la loi, a transféré à chaque niveau de collectivités des compétences (départements : collège/ commune : certains transports etc.) Au-delà des compétences qui leur ont été transférées, les communes peuvent prendre des délibérations dans toutes les affaires la concernant, les affaires locales, dans toutes les affaires ayant un intérêt local. Cela veut dire que la loi, aujourd'hui dit aux communes ce qu'elles doivent faire. Les collectivités ont une liberté limitée car elles sont financées par l'Etat. C'est la raison pour laquelle, dans certaines communes il y a des cinémas municipaux, bars ou restaurants municipaux, en utilisant la **loi générale de compétence**. C'est sur ce fondement que les communes subventionnent des associations. -> **4 éléments**

Les établissements publics : Il faut distinguer établissements publics et collectivités territoriales. Il y a trois grandes catégories de personnes morales de droit public (Etat, établissement et collectivités territoriales) Le premier problème est qu'il y a des différences qui tendent à s'estomper, le 2^e problème est qu'il y a de plus en plus de ressemblances entre des établissements et les collectivités. On peut noter que, par rapport à ce qui les distingue, à l'origine, les établissements publics ne sont pas administrés par des élus et ils disposent d'un ressort territorial à l'échelle nationale. Les établissements, à l'origine n'avait **qu'une compétence**, c'est le **principe de spécialité**. Au lieu de transférer des compétences à des collectivités territoriales, il les transférait à des établissements publics (SnCF, ENA). En effet, il y a une seule ENA, une seule SNCF qui ont une seule compétence (transport voyageur). Néanmoins, la décentralisation fonctionnelle s'est développée et a remis en cause ce qu'on vient de voir (voir III) ; en effet il n'y a plus qu'une seule université et elles ont de nombreuses compétences toutes. Même si le domaine reste celui de l'enseignement supérieur, il y a une diversité des missions, également, il y a un conseil d'administration à l'université et il est élu ; on parle ainsi de **démocratie administrative** qui fait de nous des acteurs importants. Avec ces formes modernes de décentralisation, la distinction est très relative. Aussi, le fait que les départements et les régions ne disposent plus de la clause générale de compétence, invite à constater le rapprochement entre collectivités territoriales et établissements publics. Comme on a des départements et régions qui se contentent d'exercer des compétences que la loi leur a attribué, on dira qu'en tant que collectivité, elles sont soumises au principe de spécialité.

Enfin, il y a l'émergence et la généralisation des EPCI : **E**tat **P**ublics de **C**oopération **I**ntercommunale. C'est une nouvelle catégorie d'Etat publics dont le fonctionnement fait penser à celui des collectivités mais ne l'est pas. Ceux sont des hybrides. Par exemple, la métropole, en effet, elle construit des logements sociaux, ramasse les ordures... La métropole Aix Provence est un exemple d'EPCI. On n'a pas voulu obliger les communes à fusionner donc, on a créé ce type de structure pour les obliger à mener ensemble des politiques publiques.

La **décentralisation territoriale** est la politique par laquelle l'Etat transfère des compétences à des collectivités territoriales qui s'administrent librement par des conseils élus.

La déconcentration n'implique pas de transfert de pouvoir mais implique un transfert dans la prise de décision à l'intérieur d'une même personne morale étatique (plus le gouvernement mais le préfet). Il ne faut pas confondre décentralisation et délocalisation.

2. Histoire de la décentralisation

Il y a une histoire ancienne et récente.

- L'histoire ancienne : l'histoire institutionnelle française est marquée par un mouvement de balancier, d'aller-retour entre centralisation et décentralisation. La centralisation est extrêmement forte au lendemain de la révolution dû aux volontés d'égalité, de mettre fin aux privilèges locaux. La France, avant la révolution s'est construite avec une fragmentation des droits locaux (droit de l'église, des corporations...). La Révolution française va contrecarrer cette fragmentation en égalisant les impôts etc. La Révolution française c'est donc la centralisation pour la volonté d'égalité mais aussi de cohésion nationale. En effet, au départ il y avait peu de chances qu'on fasse de la décentralisation ou encore de fédéralisation. En matière de fédéralisation, on pourrait parler de décentralisation politique ; on transfère des compétences législatives. On parle en **France d'Etat Jacobin**. Malgré tout, il y a eu des tentatives très tôt de décentralisation qui n'ont pas abouti. Il y avait cette opposition entre les jacobins (centralisateur) et les girondins (presque fédéraliste). Dès 1830, sous la monarchie de Juillet, il y aura des mouvements pré décentralisateur. En effet, il y a les premières élections municipales. **Tocqueville dit « les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple, elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. »**. Entre 1830 et 1848, la monarchie est plus libérale. Après deux régimes très centralisateur (1^e empire : napoléon et la restauration), l'Etat commence à lâcher **leste** et commence à habituer un certain nombre d'administrés à la liberté politique. Sous le second empire on recentralise. C'est à partir de la **III^e république** qu'on va mettre en place les vraies **mesures décentralisées**. C'est à partir de la **loi du 10 août 1871**, qu'on peut parler de décentralisation car on a le suffrage universel masculin et on organise des élections départementales. On va aussi commencer à transférer aux communes et aux départements certaines compétences. Notamment aux communes la gestion des bâtiments scolaires, également elles pourront mettre en place les premiers réseaux électriques... On ne peut pas parler de décentralisation au sens moderne du terme car les collectivités territoriales restent soumises à la tutelle de

l'Etat, qui est une tutelle exercée par le préfet du département. Dans le cadre des peu de conséquences qui étaient transférés aux autorités locales, le conseil local, le conseil général, pouvaient prendre des décisions mais toutes pouvaient être suspendues par le préfet local. L'Etat, à travers son préfet, pouvait effectuer un contrôle d'opportunité politique prise par les autorités (contrairement à aujourd'hui où il y a simplement un contrôle de légalité).

- L'histoire récente : elle commence en 1982, de la décentralisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a 2 observations à faire, on accoutume de présenter cette histoire en la découpant en acte. On peut parler de 4 actes de décentralisation. La décentralisation reste un processus continu, chaque année, il y a des lois, des réformes qui concernent la décentralisation. Il y a eu 4 grandes périodes durant lesquelles il y a eu des réformes importantes.

1. Le **premier acte** commence en **1982** et se termine **1986**. (C'est une période un peu particulière, le général De Gaulle avait failli lancer à la fin des années 1960 une grande réforme qui n'a pas eu lieu.) **Mitterrand** promet une grande loi de décentralisation, après être élu en 1981, ses réformes sont connues comme étant les lois Defferre (maire de Marseille, ministre de l'Intérieur qui est à l'origine des textes de lois de décentralisation (la plupart entre 1982 et 1983 surtout celle du 2 mars 1982). Il y a eu la création des régions en tant que collectivités territoriales, et les élections régionales en 1986, le principe de l'élection de l'exécutif de toutes les collectivités, élu par l'Assemblée. Également, il y a 2 évolutions majeures : on met en place une fonction publique territoriale (les fonctionnaires seront non seulement employés par l'Etat mais aussi par les collectivités territoriales (création de fonction publique territoriale) ou encore par les hôpitaux). On met aussi en place, par la loi, de nouveaux et importants transferts de compétences. Une loi va répartir par blocs/matières, les compétences aux départements, aux régions et aux communes (voir C.1.). Enfin, il y a la suppression de la tutelle, on remplace la tutelle par un contrôle juridictionnel.

2. Le **deuxième acte** débute en **2003** avec **Jacques Chirac**. On est ici d'avantage sous des réformes constitutionnelles, contrairement à Mitterrand qui adopté des lois. La révision constitutionnelle a au départ une portée symbolique dans le sens où, on va inscrire dans **l'article 1^{er} de la constitution** « **La France a une organisation décentralisée** ». En revanche, il y a quand même, dans le cadre de cette révision, des réformes plus utiles notamment une réforme de l'outre-mer : l'idée était de donner la possibilité aux populations d'outre-mer d'organiser des référendums pour décider de leur avenir institutionnel, l'idée était que, du fait qu'ils soient éloignés, on prenait en compte ces contraintes pour qu'ils aient une marge de manœuvre afin de s'adapter. Enfin, en 2003, il s'agit de renforcer l'autonomie financière des collectivités. A l'époque, pour se financer, les collectivités territoriales avaient l'autorisation, de collecter des impôts. Il y a donc eu une inscription de règle dans la constitution pour approfondir l'autonomie dans le cadre fiscale (ex : taxes de séjour).

3. **L'acte trois** débute en **2010** jusqu'en **2015**. On est sur une logique initiée par **Nicolas Sarkozy** et poursuivie par **François Holland**. Contrairement aux deux précédents actes, il s'agit de limiter les effets de la décentralisation, de la rendre moins couteuse, plus intelligible pour nous. Il y a trois lois à connaître : la première est le 16 décembre 2010, la RCT : **R**éforme des **C**ollectivités **T**erritoriales (Sarkozy) ; le 27 janvier 2014, la loi sur les métropoles (Holland) ; et

le 16 janvier 2015, la loi sur le découpage des régions et enfin, la loi du 7 août 2015, la loi NOTR : **N**ouvelle **O**rganisation **T**erritoriale de la **R**épublique. L'idée est de faire des économies, de simplifier le millefeuille territorial, le schéma institutionnel et opérer une forme de rationalisation dans l'exercice des compétences par les collectivités. Pour les économies, l'Etat **réduit la dotation globale de fonctionnement**, sur trois ans, l'Etat vote un budget avec 11 milliards d'euros en moins pour les collectivités : elles vont devoir moins recruter et moins dépenser. Pour rationaliser l'exercice de compétence, on supprime la clause générale de compétence des départements et des régions (NOTR).

4. Le **quatrième acte** de la décentralisation : 2017 fin du mandat d'Holland et début de celui de Macron. Il y a un droit à la différenciation qui a été organisé durant l'acte 3 et il s'agit d'y donner une portée plus importante. L'idée est de laisser les collectivités territoriales plus libres dans l'exercice de leurs compétences. Depuis les origines de la décentralisation, l'Etat fixait les compétences mais, l'idée c'est que tout en gardant ces compétences, elles peuvent désormais choisir, par la loi contractuelle, les compétences qu'elles souhaitent exercer. Depuis l'acte 3, les départements d'une région peuvent contractualiser avec cette région. Il y a la possibilité pour une région de récupérer la compétence des transports scolaires. Il pourrait y avoir dans le cas de certaines collectivités, une recentralisation ou une réétatisations d'une compétence : l'Etat peut récupérer une des compétences sociales (comme celle de Seine Saint Denis). L'idée est à terme d'avoir une différenciation dans le cadre de l'exercice de compétence. Les départements ne sont plus en mesure de les gérer. Il y a aussi l'idée d'expérimentation qui pourrait être pérennisées. Au début des années 2000, dans le cadre de l'acte 2, on a intégré dans la constitution la possibilité pour les collectivités d'expérimenter une loi. Cela s'est très peu fait, par exemple, avant de mettre en place le RSA, on l'a expérimenté en Alsace et ça a été l'occasion pour l'Etat de faire de ces collectivités les collectivités avec les compétences principales d'abord. Après que cela ait fonctionné, elle a été approuvée. Il ne faut pas confondre cette expérimentation qui n'a pas véritablement mis en œuvre, avec d'autres types d'expérimentations qui sont assez proches.

L'Etat a expérimenté des lois, en dehors du cadre de la décentralisation. Notamment la mise en place à Paris, à Strasbourg, à Marseille, de salle de consommation à moindre risque « salle de shoot », la possibilité d'ouvrir des établissements médicaux sociaux pour accompagner les gens dans leur consommation afin de les faire sortir avec une démarche sanitaire et sociale. L'idée est de réduire les infections. Cela est expérimenté mais pas au sens de la décentralisation.

Par rapport à l'expérimentation qu'on souhaite développer dans le cadre de cet acte 4, il y a une procédure facilitée permettant **d'accélérer les autorisations législatives, permettant à ces collectivités territoriales, à celles qui le souhaitent, d'appliquer une nouvelle loi ou de mettre en place une politique qui n'est pas prévue au niveau national.**

Cette approche qu'on pourrait qualifier d'assez libérale peut faire penser à une forme de fédération, néanmoins, ce n'est absolument pas le cas. C'est une application temporairement d'une expérience. L'idée est de généraliser cette nouvelle politique ou de la réserver aux collectivités territoriales qui la voudrait.

Il y a 2 éléments conclusifs au regard de cette histoire : l'équilibre est très fragile entre autonomie, décentralisation d'une part et, jacobinisme étatique et frilosité des élus. Pour celui ou celle qui travaille sur la décentralisation, on constate depuis 20 ou 30 ans les mêmes difficultés ; il y a des élus locaux qui veulent plus d'autonomie, et se plaignent que les règles viennent de Paris et l'état jacobin ; de l'autre côté ; les élus soupçonnent que l'Etat transfère les compétences sans l'argent qui va et ils sont donc réticents : les élus locaux ont peur : qui dit de grands pouvoirs implique une grande responsabilité. Plus on transfère les compétences, plus ils seront responsables. Combien de maires ont été condamnés en vu de leur responsabilité engagée.

Condamnation pour négligence, mise en danger de la vie d'autrui, homicide involontaire etc.

3- Les grands principes de la décentralisation

Le droit de la décentralisation est traversé par une tension fondamentale entre 2 exigences à priori contradictoire : la première c'est l'unité, l'égalité et le principe de l'autonomie et des libertés locales. Cette contradiction est inscrite à l'article 1^{er} de la Constitution « la France est une république indivisible... son organisation est décentralisée. ». Un juriste dirait que ce n'est pas contradictoire, les communautés n'ont pas de compétences législatives donc le caractère de l'Etat est préservé. En revanche, de manière assez pragmatique dans les faits, les libertés et l'autonomie locales vont malgré tout causer des inégalités, pas vis-à-vis de la loi mais plutôt vis-à-vis de l'accès à certaines prestations de services publics. Les collectivités sont des exécutantes, elles mettent en œuvre le service public etc. Nécessairement, il vaut mieux, au regard de certains services publics, se trouver dans une collectivité que dans une autre. L'état se doit d'assurer et de garantir une péréquation. La France décentralisée ne sera jamais un état fédéral à l'américaine. Qui dit état fédéral dit compétences législatives, en France cela n'existe pas (exceptée nouvelle Calédonie). Contrairement aux états fédéraux, il n'y a pas en France une chambre haute qui serait l'égal de la chambre basse. Dans les états fédéraux, il y a une chambre haute, qui s'appelle le Sénat or, le Sénat en France assure la représentation des collectivités territoriales selon l'article 24 de la constitution. Le Sénat est la chambre des élus locaux. Le Sénat, en France, a moins de pouvoir que l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron arrive à diriger l'état, sans avoir de majorité au Sénat, aux US, cela est quasiment impossible. On ne peut pas dire que la France est un Etat fédéral car il n'y a pas de compétences législatives aux communautés et pas de chambres hautes.

Aujourd'hui, la décentralisation et les collectivités territoriales bénéficient d'un ancrage constitutionnel, **l'article 72**, qui expose le principe de libre administration des collectivités territoriales, les différentes catégories de collectivités (communes, départements, régions et collectivités à statut particuliers (4)) ; le principe selon lequel c'est la loi qui crée les collectivités et détermine les conditions d'applications et de mise en œuvre, qui fixe le principe de libre administration. Cela prouve que les communautés ne sont pas exactement libres.

Ce principe de libre administration a 2 dimensions :

- Une dimension formelle : l'Etat/ la loi fixe les règles relatives aux libertés locales
- Une dimension matérielle : Sur le fond, ces libertés locales sont limitées sur le respect d'autres exigences constitutionnelles par le principe d'égalité (article 72 : le rôle du

préfet est mentionné et la loi rappelle son rôle de représentant de l'Etat, chargé de veiller au respect des règles de droit).

Le principe d'administration est très probablement le principe qui a entraîné le moins de censure constitutionnelle. Il n'y a pas plus de 2 voire 3 censures dans toute l'histoire de la V^e République : c'est-à-dire que dans cette relation entre unité et liberté, c'est l'unité qui l'emporte.

Par exemple, il a souvent des départements ou régions qui attaquent l'Etat en contestant le fait que l'Etat n'est pas distribué de moyens financiers équivalents à l'exercice d'une compétence. L'Etat n'est pas obligé de faire évoluer les moyens. Les collectivités l'emportent très rarement.

Le principe d'indivisibilité : comment concilier décentralisation et principe d'indivisibilité. **L'article 3 de la constitution dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple... aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. »**. La première implication est que les collectivités territoriales ne peuvent pas participer au principe de la souveraineté, elles n'ont pas de parlements etc. Sur le fondement de cet article 3, le conseil constitutionnel a toujours refusé de reconnaître l'existence d'un peuple autre que le peuple français.

Est-ce qu'il existe en France un peuple autre que le peuple français ? Le conseil constitutionnel a rappelé en 1991, à propos d'une loi qui concernait la Corse : « *le peuple corse n'existe pas au sens juridique du terme* ». Le droit constate l'existence d'un seul peuple : le peuple français et dénie donc à toutes autres peuples des droits particuliers. C'est ce qui a amené le conseil constitutionnel en 1999 et en 2021 à censurer des dispositifs en matière d'usage et d'enseignements de langues régionales et minoritaires. Les rapports entre l'Etat et les religions ont pour nécessiter d'avoir en tête le principe jacobin : il réagit vis-à-vis des cultes comme il réagit aux seigneurs locaux et aux langues locales. La France a toujours eu un problème avec cette indivisibilité.

B- Le statut des collectivités territoriales (=locales)

1- L'organisation territoriale française au sens de la décentralisation.

- 1^{ere} idée : Combien devrions-nous avoir de niveaux d'administration local dans la décentralisation (donc collectivités) ? On fait référence à ce millefeuille territorial. Quand on compare les niveaux d'administration en France à ceux des autres pays, avec une taille et une économie équivalente, la France a un niveau d'administration en plus par rapport aux autres (en trop). Il y a 4 niveaux : **le niveau communal, intercommunal, départemental et régional**. A Marseille il y en a 2 de plus par exemple : les arrondissements et le territoire (arrondissement, commune, territoire, métropole). Les personnes qui ramassent les ordures sont de la métropole, payer par elle, mais sous les ordres du territoire.

Le nombre élevé de niveau est lié à notre histoire, les paroisses sont devenues des communes etc. On a accumulé les choses sans supprimer ce qui aurait pu, un syndrome de **Diogène**. Ce nombre est lié à notre histoire mais, aussi de l'absence de volonté politique de les supprimer. Les élus locaux forment des associations qui constituent de véritables groupes de pression et empêchent notre droit d'évoluer sur ces questions.

Les élus qui dirigent les collectivités sont très bien représentés au niveau national, au sein de nos institutions qui font des réformes. Les élus locaux ont assez de levier.

Nicolas Sarkozy a fait voter une loi (supprimer par Hollande après) qui ne supprimait pas un niveau mais une catégorie d'élus : élus départementaux et régionaux composés le conseil. Il voulait mettre en place « le conseiller territorial » ; département et région fusionne et les élus se rassemblent/étaient dans les vizeurs les départements. **De nombreuses compétences départementales ont été transférés aux régions**, notamment le transport, avec les dernières lois. Si elles ne sont pas transférées aux régions, elles le sont quelquefois transférées aux métropoles. Pour supprimer un échelon, il faut réviser la constitution.

L'échelon communal et intercommunal :

Il y a en France, environ moins de **35 000 communes**. En termes statistiques, la **France regroupe 40% des communes de l'Union Européenne** car, elle se caractérise par un nombre anormalement élevé de commune, de communes rurales donc très peu peuplées. En Belgique, on a 600 communes, en Grèce, on en a 325. Le nombre élevé des communes, correspond au nombre élevé de paroisses de l'ancien régime. Au lendemain de la R2volution, alors qu'on aurait pu faire fusionner des paroisses proches, on a préféré garder cette identité communale, liée à cette identité religieuse, le découpage des communes correspond aux découpages de l'ancien régime en paroisse. 2 phénomènes sont venus rationaliser l'étage communale : 1^e celui des fusions de communes. En 2010 mais surtout en 2015, il y a eu des réformes très incitatives (pas obligatoire) pour que les petites communes se fusionnent. L'Etat les incite en proposant de l'argent en plus, également, elles ne participeront pas au remboursement/redressement des finances publiques. Il y a eu depuis 900 fusions de communes ayant supprimées environ 1150 anciennes communes.

Le 2^e phénomène qui a rationalisé cet étage communal est la modernisation de l'étage intercommunal.

L'intercommunalité doit toujours être étudié en lien avec les communes, on appelle ça la coopération intercommunale. Cette intercommunalité passe par la création d'un établissement publics. La forme juridique prise par l'intercommunalité c'est **l'EPCI** l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Il y a historiquement 2 formes d'EPCI : les EPCI sans fiscalité propre (n'existe presque plus aujourd'hui), ils sont financés par des contributions des communes membres de l'EPCI ; on est sur ce que l'on appelle des « syndicats » ; ces syndicats sont créés à la fin du 19^e, ceux sont des meubles de coopération permettant à des communes d'exercer ensemble une compétences (voir plusieurs) : notamment les transports entre les villages, création d'infrastructures des réseaux

de distribution de l'eau potable, ramassage des ordures ; on est sur une logique économique. On a toujours les SIVU (syndicats à vocation unique) et les SYVM (syndicat à vocation multiples). Les EPSI à fiscalité propre, eux, sont compétent pour prélever des impôts et donc pour se voir attribuer une part de la fiscalité locale (taxe d'habitation).

Ces EPSCI à fiscalité propre sont divisées en 4 catégories :

- **Les communautés de commune pour les regroupements de petites communes.**
- **Les communautés d'agglomération**
- **Les communautés urbaines**
- **Les métropoles** (au minimum 400 000 habitants et se distingue d'une communauté urbaine avec l'étendue des activités économiques. La métropole se caractérise par une ou plusieurs grandes villes centre.)

Pour l'intercommunalité, il y a un élément est lié à la volonté de voter contre l'émiettement communal : LA France a de nombreuses communes, on ne va pas les supprimer mais plutôt, les obliger à s'intégrer dans le cadre d'un EPC. Depuis la **loi du 16 décembre 2010, l'appartenance à une intercommunalité à fiscalité propre est devenue obligatoire.**

Également, on est parti du principe que l'intercommunalité est une source d'économie. Qui dit intercommunalité dit mutualisation des moyens, des achats, des moyens humains... Elle permet de faire des économies d'échelle.

Avec l'intercommunalité, il s'agit de faire correspondre des modes de vie avec des institutions. On parle d'institutionnalisation, on institutionnalise le fait rurales ou urbain. La décentralisation avait été pensée en fonction de nos modes de vie qui étaient tournés à l'époque autour de sa commune. Aujourd'hui notre cadre de vie s'étend au-delà de la commune. L'idée est que, alors qu'avant, les politiques étaient trop communales par exemple en termes de transports, aujourd'hui, on évolue. Etant donné qu'il s'agit d'une mutualisation des moyens, il y aura un phénomène de mutualisation de la charge financière et, à certains égards il y aura des communes gagnantes et des communes perdants : on mutualise certaines impôts... Il y a des villes qui sont dotées d'équipements qui bénéficient non seulement à ses habitants mais aussi à ceux des villes alentours et il faut donc les financer. Dans le cadre de la métropole, certains contribuables : les gens qui paient l'impôts, ont vu leur participation augmenter.

Les départements étaient la collectivité territoriale qui devait disparaître (réformes, Sarkozy et Manuel Valls). Autant ils peuvent se qualifier comme circonscription de l'Etat, aujourd'hui ils constituent un étage qui n'ont plus tout à fait leur raison d'être au moins pour une raison, **les intercommunalités ont grossi.**

Les intercommunalités ont grossi entre 2010 et 2016/2017, on a assisté à un processus d'intercommunalisation globale ; on a donc des intercommunalités dont le périmètre épouse environ la totalité du département, c'est le cas pour l'intercommunalité Aix Marseille qui épouse presque la globalité du territoire départemental.

Certains départements ont été fusionnés en tant que collectivités territoriales, comme la Corse, il n'y a plus 2 départements. Ils ont mis en place un système qui gère les affaires départementales et les affaires régionales. C'est également le cas des départements du Haut Rhin et du Bas Rhin. Il reste les départements mais ils ne composent plus qu'une seule collectivité territoriale.

Pour les régions, il s'agit comme pour les EPCI, de la collectivité d'avenir. (La décentralisation c'est construit autour du couple communes/ départements. Depuis l'acte 3 et l'acte 4, on est sur une décentralisation entre intercommunalité et EPCI : le nombre de communes a diminué, les compétences ont été transférées aux intercommunalités). Pour les régions, c'est pareil : les régions se sont agrandies, et des régions sont montées en compétences. La loi du 16 janvier 2015 a opéré cette fusion des régions : on avait en métropole 22 régions, on est passé à 13 ; certaines régions ont été renommées. Désormais, une part de la TVA est attribuée aux régions. Également, il avait été question à l'époque, de faire des régions de dimensions européennes. Comparées aux autres régions européennes, certaines ne sont pas assez grandes, pas assez peuplées etc. Il est nécessaire de bien se placer sur la scène européenne. L'union européenne, chaque année, autorise des milliards d'euros pour les régions européennes, pour développer des équipements pour participer à la rénovation de construction de lycée par exemple, de route, ce qu'on appelle les aides régionales. L'obtention de ces aides régionales est facilitée par la mise en place de ces régions plus visibles, plus grosses. Ces fonds européens devaient être réservés aux régions européennes les plus pauvres mais à tout le monde finalement.

Niveau propre à l'outre-mer : les collectivités qui se situent en outre-mer sont **les collectivités territoriales d'Outre-mer**. Ne font **pas partie** de ces collectivités territoriales d'Outre-Mer les **TAAF** (Terres Australes et Antarctiques Françaises) **EN APPRENDRE 2 OU 3**, dans la mesure où, elles ne comportent **pas d'habitants permanents**, néanmoins, c'est en partie grâce à ces terres que la France est le 2^e pays avec la plus grande zone maritime.

Il faut savoir que ce droit de l'outre-mer a été marqué par l'histoire de la conception de la république. Il y a eu ces dernières années de nombreux débats (colonisation/esclavages). Au moment où la France sort de la colonisation, on se demande que faire de ces territoires : certains souhaitent leur indépendance, d'autres veulent rester des collectivités françaises.

Il y a 2+1 (Nouvelle Calédonie) à part sous catégories : La première est la catégorie des DROM : départements et régions d'Outre-mer, qui se trouve régie par **l'article 73 de la Constitution**, il y a pour l'instant la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane et Mayotte. Depuis l'acte 2 de la décentralisation, l'idée est de rendre le référendum plus accessible pour ces populations, elles font le choix de passer d'un statut à l'autre. Ces DROM sont soumis au principe de l'identité législative ; sauf mention contraire, ces DROM se voient appliquer les mêmes lois, bénéficient des mêmes services, ont les mêmes impôts que les collectivités territoriales de métropole. Il est possible pour la loi de tenir compte de caractéristiques et contraintes de ces collectivités grâce à la loi de l'article 16. On est dans des collectivités insalubres etc. : le droit français s'adapte. Certains de ces DROM ne sont pas tout à fait des DROM, il n'y a pas forcément dans ces collectivités et un département et une région sur le même territoire, par exemple, à Mayotte, il n'y a qu'un département et le conseil

départemental s'y occupe donc à la fois des compétences départementales et régionales. La 2^e catégories : les **COM les collectivités d'outre-mer** qui sont dans l'article 74 sont soumises non pas au principe de l'identité mais au principe de spécialité législative. Il y a la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Michelon, Saint Martin et Saint Barthélemy. Il faut savoir que chacune de ces collectivités fait l'objet d'une loi organique propre. Une loi organique c'est une loi qui sans avoir valeur constitutionnelle, a un contenu dont l'objet est la mise en œuvre, le détail de certaines dispositions constitutionnelles. Chacune COM a sa propre loi, principe etc... Attention, cela reste la France, c'est le même droit dans certains domaine (pénal etc.) mais quelquefois les règles sont spécifiques (droit du travail). Ces règles spécifiques sont inscrites dans la loi organique votée par le Parlement français.

La Nouvelle Calédonie n'est pas une collectivité territoriale : c'est un pays mais pas un Etat. La nouvelle Calédonie est un pays à part qui fait partie de la France mais qui fait partie d'un titre spécifique : le titre 13 de la Constitution, article 76 et 77. Ce titre 13 est intégré en 1998 à la suite de 2 séries d'accords concluent entre le gouvernement et le local : les accords de Matignon en 1988 et de Nouméa en 1998. L'idée de ces accords de Nouméa est que, il y a eu de nombreuses violences en 1980s pour laisser la Nouvelle Calédonie accéder à son indépendance. La population indigène n'est pas majoritaire en Nouvelle Calédonie et que ceux d'origines européennes qui ne sont pas pour l'indépendance, il y a donc eu un compromis avec un statut évolutif : la Nouvelle Calédonie aura le droit de disposer de son propre Congrès, qui dans un certain nombre de domaines, adopte des lois : « les lois du pays », il y a donc un rapport fédéral. AU terme de processus, 3 référendums d'indépendance sont prévus ; 2018 le « non » l'a emporté, en 2020 le « non » l'a emporté, un reste à déterminer. Néanmoins, la France doit redéfinir les termes de ce rapport.

2- La démocratie locale

Il y a plusieurs façons d'aborder la démocratie au niveau local. Il y a la façon traditionnelle, c'est l'organisation d'élection, la vision formelle de la démocratie, tous les 6 ans il y a des élections où on élit les organes différents, différents conseils etc. Depuis maintenant une trentaine d'années, on a pris conscience que le niveau local pouvait susciter des mécanismes plus originaux. Le second niveau est donc la démocratie participative (ou délibérative). Cela renvoie à des procédures, il y a une plus large participation des administrés à la vie politique locale, à la prise de décisions au niveau local. Cette démocratie participative n'est pas très nouvelle, elle s'est inspirée en France de mécanisme qu'on retrouve dans certains autres pays, on peut penser par exemple, à Paris ou Grenoble, aux budgets participatifs. A Paris, il y a une fois par an, une consultation qui invite les Parisiens à définir un ensemble de programme, d'investissements jugés prioritaires, étant les programmes les plus plébiscités qui vont être financier. Parmi ces mécanismes, certains sont facultatifs : les budgets participatifs par exemple, mais d'autres procédures sont obligatoires en fonction du nombre d'habitants dans la commune. Plus la démographie dans une commune est élevée, plus les mécanismes seront nombreux. Quand on parle de mécanismes ce sont des conseils, conseils des quartiers dans laquelle les citoyens peuvent participer et suggérer des réformes etc. Pour ces mécanismes dont la mise en œuvre dépend du nombre d'habitants, ce sont des processus non décisionnels,

on suggère, on propose et, il y a à cet égard de nombreuses décisions suscitées par ces mécanismes. De manière plus large, tous ces processus, assez modernes et plutôt incitatifs, relèvent d'une démocratie administrative. Dans la plupart des administrations, ces processus existent ; c'est notamment le cas à l'université, les usagers peuvent participer à la prise de décisions, ils décident ici des réformes adoptées et de mesures mises en œuvre. Ce processus permet de tenir compte du fait que prendre en compte les avis des gens 1 fois tous les 6 ans n'est pas suffisant. On peut parler alors d'un usager électeur. L'existence de ces mécanismes et d'autant plus nécessaires ou d'autant plus inutiles selon le taux de participations aux élections. La mise en place de ces mécanismes est d'autant plus nécessaire que les taux de participations aux élections sont faibles. Elle peut paraître inutile. Quand on prend le bilan final, dans le cadre de la démocratie administrative, il y a environ 10% des administrés. Il s'agit de parler de la démocratie représentative au niveau local.

Le fonctionnement des communes et des élections communales :

Au niveau des communes, il y a toujours le même fonctionnement avec la même structure institutionnelle : un organe délibérant et un exécutif. L'organe délibérant (conseil municipal) est renouvelé tous les 6 ans et son nombre de conseil varie en fonction de la taille de la commune. Également, le mode de scrutin varie en fonction du nombre d'habitants.

(Les modes de scrutins sont la façon dont on va déterminer les résultats d'une élection, il va du tirage au sort jusqu'au mode de scrutin des députés en Allemagne. Selon le mode de scrutin qu'on utilise, ce n'est pas la même personne ou le même parti qui gagne les élections : Trump en est l'exemple même. Il y a une variété de mode de scrutin)

Pour les élections municipales en France, il y a un mode de scrutin spécifique dans les communes de moins de 1000 habitants, dans ce cas-là, l'électeur vote pour une liste et celle qui arrive en tête remporte tous les sièges : c'est un scrutin de liste majoritaire. Il y a tout de même des spécificités : dans ces communes-là, les électeurs ont le droit de faire un panachage, c'est-à-dire de barrer des noms et de les remplacer par des noms d'autres candidats qui sont sur une autre liste. Ces élections sont moins politisées que dans les grandes communes, on vote surtout pour la personne. Depuis la réforme de 2013, dans le cadre du panachage, on n'a plus le droit d'inscrire le nom d'un individu qui ne se trouvera pas sur l'une des listes en présence.

Dans les communes de plus de 1000 habitants, on a un scrutin qu'on qualifie de mixte car il mélange scrutin majoritaire et scrutin proportionnel. Il y a 2 tours même si les élections peuvent se terminer au premier tour si la liste arrivée en tête obtient la majorité des suffrages. La liste en tête se voit attribuer une prime majoritaire dans les deux cas. Elle obtient automatiquement la moitié des deux sièges. C'est le côté majoritaire de cette élection. L'autre moitié des sièges est répartie à la proportionnelle. Cette proportionnelle n'est pas forcément pure. Cette moitié des sièges va être réparties également à la liste qui est arrivée en tête (elle aura la majorité plus quelques autres sièges à la proportionnelle).

Par rapport à l'exécutif communal, le pouvoir exécutif dans la commune est le maire et ses adjoints. Le maire est un conseiller municipal, il va être élu parmi les conseillers municipaux « maire » au cours de ce que les médias appellent un « troisième tour » (1^e on vote, 2^e les listes se sont maintenues car plus de 5%, 3^e tour on vote le maire). De manière systématique, le maire est la tête de la liste arrivée en tête. Les retournements de situations restent rares. **Le maire est élu au suffrage universel indirect.** Le jour de l'élection du maire, sont élus les adjoints au maire auxquelles il va déléguer une partie de ses fonctions.

Par rapport aux pouvoirs, aux attributions du maire, il y a différentes séries :

- les pouvoirs propres du maire : les attributions qui ne consistent pas à exécuter des délibérations du conseil municipal, par exemple, la gestion du personnel de la commune, la délivrance des permis de construire etc. Il a aussi les pouvoirs de polices administratives. Le droit français attribue un grand pouvoir au pouvoir de police aux maires. Cela lui permet de prendre des arrêtés municipaux, qui permettent au maire de limiter nos libertés (interdiction d'acheter de l'alcool après 21h, fermeture des bars à 1h...). Ces derniers sont très contrôlés.
- les attributions exécutives : c'est l'exécution des décisions dans le conseil. La plupart des décisions communales relèvent du conseil. Au niveau local, c'est comme au niveau national : le maire gouverne, il est à l'initiative. Il gouverne en amont puis il exécute.
- 3^e série d'attribution : le maire est aussi un agent de l'Etat, à ce titre on parle de dédoublement fonctionnel, il a une double casquette, représentant de la commune et de l'Etat. Parmi ses fonctions les plus importantes, il est un officier d'Etat civil notamment pour la célébration des mariages, la déclaration des naissances etc. Au nom de l'Etat il exécute seulement. En tant qu'agent de l'Etat, les maires peuvent être **révoqués** en conseil des ministres.

En France, il y a 3 communes à statut particulier : Paris, Lyon, Marseille. Ils ont une loi spécifique.

- **Paris**, siège du gouvernement, capitale, ville avec beaucoup d'événements (révolution, commune, mai 1968). Le système particulier mis en place est de moins en moins particulier.

1^e spécificité est que Paris est à la fois une commune et un département. Le conseil de Paris est à la fois conseil municipal et conseil départemental.

2^e spécificité : les pouvoirs de police du maire sont moins importants que ceux de ces de 2 préfets

3^e spécificité : la ville est divisée en arrondissements. Dans chaque arrondissement, il y a un conseil. Une partie des conseillers d'arrondissement (1/3) siège au conseil de Paris. Il y a une organisation très particulière, il y a un conseil par arrondissement élu par les électeurs et en fonction du résultat de ces élections, les représentants ne sont pas élus de la même fonction au suffrage de Paris.

Les conseils d'arrondissement à Paris (20 arrondissements), Marseille (16 arrondissements) ou Lyon (9 arrondissements), sont compétents dans certains domaines comme celui de l'entretien et la gestion des écoles primaires. C'est la décentralisation dans la décentralisation.

Les élections intercommunales ou communautaires ou l'élection des conseillers communautaires :

La loi du 17 mai 2013 a généralisé le principe de l'élection des conseillers communautaires. Le jour de l'élection municipale, l'électeur fait 2 votes, le 1^e pour la liste et le deuxième bulletin pour le conseil de L'EPCI. Au sein de chaque inter communauté, on est au sein d'un groupement de commune. Il y a donc plusieurs représentants des communes mais, le nombre de conseillers varie en fonction du nombre d'habitants. **Les conseillers communautaires sont aussi conseillers municipaux**, certains sont les 2. Si on vit dans une petite ville, il y aura 1 seul représentant.

Les élections dans les départements et les régions

Les conseils départementaux sont, en France, totalement paritaires. Le mode de scrutin a été modifié en 2013 et, c'est un scrutin binominal majoritaire, paritaire, à deux tours. Tous les 6 ans, il va y avoir la possibilité de voter pour un binôme : 1 homme avec un suppléant homme et 1 femme avec suppléant femme. Si la composition du Conseil est paritaire, la présidence ne l'est pas. Pour l'élection départementale, le département est divisé en canton qui est une subdivision électorale d'un département. Il y a le même principe que pour les communes avec un 3^e tour.

Pour les élections régionales, il y a également le 3^e tour comme dans les communes et départements. Le mode de scrutin est le même que celui des élections municipales dans les communes de plus de 1000 habitants à une exception près, la prime majoritaire n'est que de 25% ce qui multiplie d'autant plus les stratégies électoralistes.

Conclusion : On est dans un domaine qui a fait l'objet de nombreux tâtonnements. Il y a énormément de réformes qui expriment une sorte de désillusion. Lorsqu'on regarde les textes, qu'on écoute les débats parlementaires, il avait été question de **faire de la décentralisation le laboratoire de la démocratie locale**. On peut néanmoins mettre en lumière l'échec car mises à part des élections municipales, les autres élections ont eu une forme de boudage. Il y a eu beaucoup de réformes notamment en 2017 et 2021 ayant pour objet d'esquisser un statut de l' élu local. Les élus locaux ont un statut pas si avantageux que ça. Lorsqu'on a commencé à mettre en place la décentralisation, il faut savoir que ces élus locaux ne bénéficiaient d'aucune gratification, ce qui progressivement a évolué, on a commencé à mettre en place un statut de l' élu local avec des droits et des obligations. Encore aujourd'hui, les élus municipaux ne reçoivent que des simples (petites) indemnités d'où la crise de la

vocation. L'idée est de rendre plus attractif le « métier » d' élu local. On oscille dans cette volonté de faire un vrai statut de l' élu (indemnité + sécurité) ou bien, de ne pas en faire un métier ce qui permet de mieux renouveler le personnel politique local et donc donne plus de chance à plus d'individu. Néanmoins, avec la technocratie, il y a un appui sur les collaborateurs. Ce sont des emplois fonctionnels.

C. LE FONCTIONNEMENT DE CES COLLECTIVITÉS

1. LES COMPÉTENCES

Qui fait quoi ?

La première idée, est que rares sont les compétences locales qui relèvent d' une catégorie de collectivité ; la plupart des compétences sont exécutées de manière partagée. On peut parler d' un véritable enchevêtrement des compétences des collectivités.

EX : sur la compétence scolaire (l'entretien des bâtiments, la gestion du personnel non enseignant) on est sur une répartition des 3 niveaux de collectivités.

Au lieu d'attribuer une compétence a une catégorie de collectivité, on a saucissonné les compétences locales. Le but a été de trouver le bon niveau d'administration. Cet enchevêtrement, étant un choix rationnel, a aboutie à une tentative de clarification qui a commencé a partir de l'acte 3 de 2010, étant un acte de rationalisation des compétences.

Sur l'acte 1 de la décentralisation, il y a 2 lois importantes : celle du 7 janvier 1983 et celle du 22 juillet 1983. Ce sont des lois de compétences avec un transfert de matière ou un transfert dit par « blocs ». l'Article L111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : *« la répartition des compétence s'effectue dans la mesure du possible de tel sorte que chaque domaine de compétence, ainsi que les ressources correspondantes soient affectées en totalité soient aux communes, soient aux départements, soient aux régions »*. L'idée de départ était de transférer des blocs et de spécialiser les compétences des collectivités territoriales. C'est pas du tout ce qui a été fait. Cet article ne correspond donc pas a la réalité. Cet état des choses a été rendu d' autant plus compliqué, le fondement du principe de libre administration ai été accordé à tous les niveaux de collectivités, appelé « la clause générale de compétence ». Cette clause se traduit par le fait que la loi va transférer des compétences aux collectivités, même dans les domaines non transférés, les collectivités peuvent intervenir sous réserve qu'elles justifient d' un intérêt public local : on va répartir précisément des compétences aux collectivités et on va les laisser intervenir dès lors qu'elles justifient d' un intérêt public local. Cette clause, ne permettant pas aux collectivités de tout faire : dans tout une série de domaine elles n' interviennent que faute d' initiatives privées.

EX : les restaurant municipaux, les bars municipaux

Plusieurs lois se sont succédé durant l'acte 2 et 3 pour la répartition des compétences et la principale étant une loi « NOTRE » du 17 aout 2015 qui a eu 2 objets : la suppression de clause générale de compétence des départements et des régions et la consécration d' un principe de spécialisation de compétences. Tout n' a pas été spécialisé.

EX : pour la région, on est sur des compétences a vocation principalement économique, tout ce qui relève des aides aux entreprises, de la formation professionnelle, de l'apprentissage (question de transport et environnementale).

Pour les départements c'est une spécialisation dans le domaine de l'action sociale.

EX : les aides aux personnes handicapées, personnes âgées, etc...

Pour les communes et les intercommunalités, on a l'aménagement de l'espace (documents de planification qui vont déterminer certains aménagements et toutes les règles concernant le droit à l'urbanisme) ou encore tout ce que sont les services publics de proximités ou on retrouve la question des transports, la politique de l'habitat, le ramassage des ordures, les réseaux d'assainissement et de distribution de l'eau potable.

2) LES MOYENS

Il existe plusieurs séries de moyens :

- **1ère série** : les moyens matériels : biens soumis a un régime juridique exorbitant auquel on a assister ces dernières années pour qu'elles puissent valoriser ce patrimoine. Il y a des modes d'acquisitions exorbitants de ce patrimoine. Le droit de préemption est un autre moyen exorbitant. Concernant les modes de gestions de ces biens, depuis quelques années, les collectivités tirent énormément de revenus de leurs biens : plus le temps passe et plus c'est le cas. On appelle cela les produits du domaine ou les redevances issus de ce domaine.

EX : depuis 2014, les frais de stationnement que l'on paye vont directement à la commune.

L'idée est de trouver un maximum de source de revenu pour aider les collectivités territoriales à s'exercer. Il y en a beaucoup.

- **2ème série** : les moyens financiers : les finances locales (les produits du domaine en font partie). Jusqu'à présent, il n'est pas possible de parler d'une autonomie fiscale des collectivités territoriales dans la mesure ou elles n'ont pas le droit de créer des impôts. En revanche, elles bénéficient, sur le fondement de la Constitution Article 72-2, d'une autonomie financière. Elles sont capables de se procurer des revenus dont la recette est significative et doit être déterminante. C'est la capacité que devrait avoir les collectivités de se financer sans l'aide de l'Etat. Les ressources propres doivent constituer une part déterminante de leurs ressources financières. Cette autonomie financière est relative dans la mesure ou l'Etat procure aux collectivités l'essentiel de leurs ressources. Ce moyen financier attribué par l'Etat aux collectivités, s'appelle la Dotation Globales de Fonctionnement (DGF). Il y a des collectivités autonomes financièrement et qui reçoivent très peu de dotations de l'Etat car elles ont le moyen de se financer elles-mêmes. Si on fait le bilan général, les collectivités ne sont pas autonomes : elles reçoivent davantage de l'Etat de ce qu'elles sont en mesure de se procurer par elle-même, sachant que ce qu'elles sont en mesure de se procurer dépendent des lois étatiques.

EX : la suppression de la taxe d'habitation, diminution de 12 milliards de la DGF, sous Hollande.

Il y a la loi du 22 janvier 2018 qui est venue contractualiser les modalités de participation des collectivités à l'assainissement des comptes publics. L'Etat a imposé un contrat à plus de 3 collectivités (départements, régions et grandes communes) le but étant d'obliger les collectivités à réduire leurs dépenses et si elles ne réduisent pas leurs dépenses elle verront leurs DGF diminuer. Enfin, la jurisprudence administrative et constitutionnelle a toujours été défavorable aux collectivités territoriales. Il arrive au Conseil constitutionnel et au Conseil d'Etat, des contentieux où les collectivités attaquent l'Etat. Les collectivités profitent de l'adoption de nouveaux textes pour contester le fait que l'Etat ne transfère pas les moyens financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences.

EX : le RSA

- **3ème série :** les moyens humains : on parle généralement de la fonction publique, et ici de la fonction publique territoriale, mais tous ceux qui travaillent pour les collectivités ne sont pas fonctionnaires. Le terme générique est celui d'**emploi public** qui désigne les emplois en France qui sont proposés par les personnes publiques. L'Etat n'est pas le seul employeur public, si on devait simplifier il y en a 3 en France et à ces 3 employeurs correspondent 3 fonctions publiques :
- L'Etat -> la fonction publique de l'Etat
- Les établissements publics -> la fonction publique territoriale
- Les collectivités territoriales -> la fonction publique hospitalière

Avant de parler de la Fonction Publique Territoriale, tous ceux qui travaillent pour des personnes publiques ne sont donc pas des fonctionnaires, le terme générique lorsque l'on parle d'une personne publique sont des **agents publics** divisés en 2 grandes catégories entre les fonctionnaires et les contractuels (des titulaires d'un contrat mais ne sont pas soumis au statut de la fonction publique). Historiquement, la France fait partie des pays qui ont fait le choix de mettre un statut spécifique pour ceux travaillant pour l'Etat, pour permettre aux fonctionnaires soumis à ce statut, d'être indépendant non pas du pouvoir politique mais indépendant des personnes incarnant ce pouvoir politique, que l'on va protéger en les intégrant dans un statut spécifique de la fonction publique, fait de droits et d'obligations. Parmi les droits, il y a notamment toute une série de protections mises en œuvre pour les fonctionnaires.

EX : la protection fonctionnelle qui permet dans le cadre de la fonction s'il y a un accident, d'être pris en charge par la protection fonctionnelle.

Les fonctionnaires n'ont pas un emploi à vie, mais dans les faits c'est plus compliqué de se débarrasser d'un fonctionnaire (qui peut être révoqué) que d'un salarié (qui peut être licencié). À ces droits, on a des obligations particulières :

EX : l'obligation de neutralité (pas d'éléments religieux par exemple), un devoir de réserve (il est plus compliqué pour un fonctionnaire de critiquer son employeur que pour un salarié de critiquer son chef) (les militaires ont un strict devoir de réserve). => statut très protecteur.

Les personnes publiques ont la possibilité de recruter par contrat, c'est la tendance. A l'avenir il y aura moins de fonctionnaires puisque beaucoup d'agents publics vont être recrutés par contrat, notamment par les collectivités territoriales. Il y a d'ailleurs eu des abus dans le cadre du recrutement depuis 1982, avec des emplois publics créés pas nécessairement pour des besoins mais pour répondre à des liens d'amitiés ou électoraux.

EX : on va avoir des emplois publics en contrepartie de recevoir des voix électorales lors de l'élection, par exemple.

En principe, il y a des règles, notamment pour pouvoir recruter des fonctionnaires : il faut des concours, mais il existe beaucoup de dérogations. Il y a donc une incitation de recruter par contrat pour des garanties de flexibilité. A l'avenir ce sera des contrats de mission. Il y a des recours de contractualisation et de précarisation de l'emploi public. Quand on recrute un fonctionnaire on ne lui fait pas signer de contrat, il est soumis au statut de la fonction publique. Dans le cadre des collectivités territoriales c'est une fonction qui a été mise en place dans le cadre de l'acte 1, avec la loi du **26 janvier 1994** qui a créé la Fonction Publique Territoriale (FPT). Il y a environ 1,9 million d'agents publics territoriaux pour les FPT. La FPT se caractérise par un taux très important de femmes : on est à un peu moins de 80% de femmes dans la FPT, expliqué par un certain nombre de phénomènes sociaux. On est sur des emplois peu rémunérés : sur 80% des agents publics sont des agents de catégorie C. - catégorie A -> emplois de direction

- Catégorie B -> emplois de mise œuvre
- Catégorie C -> emplois d'exécution (1400 à 1500euros/mois)

Le principe de libre administration autorise les collectivités à créer des emplois selon leurs besoins. En revanche, la liberté est loin d'être totale car il y a des limites financières mais également au niveau de l'emploi territoriale il y a des règles assez rigides en termes de concours à respecter. En principe, un fonctionnaire ne peut être recruté que dans le cadre d'un concours, qui sont principalement réservés aux emplois A et B. Il y a une certaine rigidité dans le cadre de l'évolution de la carrière, un fonctionnaire évolue à l'ancienneté et au mérite, il existe aussi le système des primes (+ de responsabilité donc + de primes).

On a l'équivalent de l'ENA dans le cadre de Fonctions Publiques Territoriales que l'on appelle les

Institutions Nationales Spécialisées d'Etudes Territoriales (ISNET).

- **4ème série** : les moyens juridiques : les collectivités disposent de 2 catégories de moyens juridiques :
- Des **moyens contractuels** : les contrats conclus par les collectivités sont d'une très grande variété. On parle de contrats publics ou administratifs comme les marchés publics et les délégations de services publics, tous ces contrats ne sont pas nécessairement soumis au droit public (en principe c'est le cas). Avec le temps, les règles de passation des contrats publics ont eu tendance à se rigidifier car il a pu y avoir des abus. Ces contrats ont pour effet d'être concernés par l'argent public, l'idée est alors d'éviter que ceux qui signent ces contrats aient un intérêt purement privé.

- Des **moyens unilatéraux** : pour les collectivités, comme toute personne publique, elles peuvent produire du droit unilatéralement, soit toute seule. Cette production unilatérale du droit est ce que l'on appelle une **prérogative de puissance publique**. Ce droit unilatéral, on le désigne sous l'acronyme **AAU** (Actes Administratifs Unilatéraux). Cette production d'AAU est rendu possible par l'Article 72 de la Constitution : « *les collectivités disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.* ». Le pouvoir réglementaire est un pouvoir qui consiste à produire des normes générales, c'est-à-dire qui s'appliquent à tous.

EX : le plan local d'urbanisme est une norme générale

A côté de ce pouvoir réglementaire général, il y a aussi des décisions individuelles prises par les collectivités qui ne veut pas nécessairement dire que cela concerne un seul individu. Ce sont des décisions qui ont des destinataires identifiés ou identifiables. => décisions individuelles exécutoires

3) LE CONTROLE DE L'ÉTAT

La forme du contrôle de l'Etat a beaucoup évolué depuis l'acte 1 de la décentralisation, c'est d'ailleurs la loi du **2 mars 1982** qui a profondément modifié les modalités du contrôle : on est passé d'un contrôle d'opportunité à un contrôle de légalité. En toute hypothèse, il y a un contrôle. **Quelle est la différence entre ces 2 types de contrôle ?**

Le contrôle d'opportunité qui a quasi disparu, était un contrôle a priori forcément motivé par des raisons juridiques.

EX : lorsqu'une collectivité recrutait un individu, avant que l'acte de recrutement entre en vigueur, il y avait un contrôle effectué par la préfecture et le préfet pouvait a priori empêcher l'entrée en vigueur de l'acte, uniquement pour des raisons d'opportunités. Ce contrôle d'opportunité a été remplacé par le contrôle de légalité, prévu à l'Article 72 de la Constitution, selon lequel « *Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.* ». Cet article peut laisser penser que le préfet contrôle lui-même l'application des lois. C'est le cas : il peut contrôler les actes des collectivités mais il n'a plus le pouvoir d'empêcher l'entrée en vigueur de l'acte.

EX : si le préfet considère que le processus de passation de marché public a violé

La loi, il ne peut plus l'annuler. Il est obligé de déférer l'acte au tribunal administratif, c'est ce que l'on appelle le **déféré électoral**.

Il s'agit d'un contrôle à posteriori, dans le sens où l'acte entre en vigueur même s'il n'a pas été contrôlé, il rentre en vigueur dès lors que l'acte est transmis au préfet. Le déferrement n'est pas une obligation. Dans les faits, 0,01 % des actes des collectivités sont contrôlés effectivement par les préfectures. Le préfet ne contrôle pas tout puisqu'ils en n'ont pas les moyens humains et tous les actes des collectivités ne leurs sont pas transmis. Il y a une liste d'acte à transmettre :

EX : les marchés publics sont des actes transmis

Tout a chacun, peut, à certaines conditions, contester, devant la justice administrative, les actes des collectivités. En général on a 2 mois pour contester, après publication si c'est un règlement ou après notification si c'est un acte individuel. En général, il s'agit d'exercer un **Recours pour Excès de Pouvoir (REP)**.

3) LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET LES AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : ils constituent la 3ème grande catégorie de personne morale de droit public. On parle de décentralisation, mais il s'agit là, de la décentralisation fonctionnelle et non territoriale. Il s'agit de créer cette catégorie d'établissements pour leur conférer, au départ une compétence, c'est pourquoi on parle d'un **principe de spécialité**.

EX : la RATP, le Commissariat de l'Energie Atomique (CEA), CNRS, etc...

On a des établissements qui se sont multipliés dans la même catégorie.

EX : les hôpitaux publics, les universités, etc...

L'établissement public constitue une sorte de démembrement de l'administration : on va créer une personne qui va exécuter une autorité administrative. On va autonomiser un service public. Selon **Morris Hauriou**, « *l'établissement public est un service public personnifié* », on crée une personne qui va être démembrée et va exercer ses services publics, l'établissement public est un mode de gestion de service.

EX : au lieu de le gérer directement, l'Etat délègue la compétence d'enseignement universitaire aux universités

Certes, l'établissement public est doté d'une certaine autonomie, il y en a des plus autonomes que d'autres, on parle d'une **autonomie organique**. Cette autonomie varie d'une catégorie d'établissements publics à d'autres, qui reste une autonomie limitée.

EX : on ne peut pas comparer le degré d'autonomie des universités à celui des hôpitaux

En principe, les établissements publics sont soumis au **principe dit de rattachement**. La plupart des établissements publics sont rattachés à une autre personne publique.

EX : le lycée ou les hôpitaux sont des personnes publiques qui sont rattachées à la région et à l'Etat.

C'est ce rattachement qui permet de réduire l'autonomie fonctionnelle des établissements publics.

EX : l'UE 7

Il existe maintenant deux grandes catégories d'établissements publics :

- Les Etablissements Publics Administratifs (EPA)

- Les Établissements Publics à caractère Industriel et Commerciaux (EPIC).

Au départ il y avait que des EPA, mais en **1921**, le tribunal des conflits a rendu une décision appelée « *société commerciale de l'ouest africain* » (appelé aussi arrêt BAC d'Eloka) qui a dégagé une distinction entre les Etablissements Publics Administratifs (EPA) et Établissements Publics à caractère Industriel et Commerciaux (EPIC). Le tribunal de conflit est chargé de trancher des conflits de compétences. Les premiers EPIC sont soumis au droit public alors que les derniers sont soumis au droit privé. On distingue les EPA et EPIC par la loi, mais également selon des critères tels que la nature de l'activité ou le financement.

EX : l'université a pour activité l'enseignement, c'est donc un EPA car sa mission a un objet de service public intuitif, son financement, quant à lui, laisse aussi à penser qu'on est dans une EPA

Quand on a une activité ayant une nature traditionnellement administrative, avec un mode de financement qui est celui de l'Etat ou de l'impôt, on se trouve dans les EPA.

Un EPIC correspond alors à l'inverse d'un EPA, qui va avoir une activité moins administrative et plus industrielle et commerciale.

EX : la RATP est un EPIC, payé par l'usagé

LES ENTREPRISES PUBLIQUES : elles ne sont pas toutes nécessairement des personnes de droit morale de droit public, leurs régimes juridiques varient en fonction de la loi : c'est la loi qui va leurs donner la qualification de personne morale de droit public ou de droit privé. Elles peuvent prendre deux formes différentes :

- Des EPIC : partiellement privatisés
- Des sociétés commerciales : personne morale de droit privé, totalement privatisés

En réalité le point commun entre toutes cette entreprise publique est qu'elles ont des liens avec le secteur public et avec le secteur privé. Ce sont au départ des structures créées par l'Etat mais qu'on a du partiellement voir totalement privatisé. L'idée est d'adapter le fonctionnement de ces entreprises aux règles de la liberté des concurrences.

EX : France télécoms, EDF et GDF, la société aéroport de Paris, la SNCF (qui est passé du statut d'EPIC au statut de société en 2020)

Il s'agit d'adapter nos entreprises publiques aux règles de la liberté de la concurrence. La France a été particulièrement touchée par ce mouvement de privatisation, car on a toujours eu la tradition d'une intervention dans le secteur économique de l'Etat. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'Etat providence, mais on a dû s'adapter aux règles de l'UE, qui, sans être hostile à la présence de l'Etat, a impliqué le respect de l'initiative privée et donc de la concurrence. Ce phénomène de privatisation n'est jamais absolu, il y aura toujours un lien avec les secteurs publics, qui peut se matérialiser par la présence de capitaux publics.

EX : l'Etat est actionnaire de la SNCF, on retrouve donc des capitaux publics dans cette société anonyme.

La privatisation peut entraîner une transformation d'un établissement public administratif en établissement public à caractère industriel et commercial. On transforme donc l'EPA en EPIC, mais dans ce cas, ce que l'on va privatiser, ce sont les règles que l'on va appliquer. Ce qui va commencer par l'impossibilité de recruter des fonctionnaires, on va donc recruter des salariés avec des contrats de droit privé. Ainsi, le terme de privatisation ne signifie pas toujours la soumission de l'établissement public ou de l'entreprise à des règles de droit privé.

LES GROUPEMENTS D'INTERETS PUBLICS (GIP) : regroupements, associations d'organismes publics ou privés dans le cadre d'un secteur déterminé.

EX : dans le domaine de la recherche scientifique, l'idée est d'associer des acteurs privés et des acteurs publics pour améliorer la qualité de la recherche et engager des capitaux ; il en est de même dans le domaine de l'enseignement supérieur ou dans le domaine de la formation professionnelle dans les sites pénitenciers.

LES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES « SUI GENERIS » : outre ces personnes morales de droit public qui ne se rattachent à aucune catégorie, on pourrait parler de personnes publiques dites « sui generis » (= de sa propre espèce).

EX : la banque de France est une personne morale de droit public, qui a un rôle limité mais qui a été conçue à l'origine pour émettre la monnaie : le franc ; la caisse des dépôts et consignations (institutions intervenant dans le domaine financier) ; l'opéra de Paris ou encore l'Institut de France créée par Richelieu qui représente les 5 plus grandes académies, sont des institutions administratives dites « sui generis ».

LES AUTORITÉS INDÉPENDANTES : l'idée de reconnaître une autonomie très poussée à certaines autorités administratives n'est pas une nouveauté. Ça a toujours existé.

EX : parmi des autorités administratives plutôt indépendantes sans recevoir cette qualification, il y a des jurys de concours qui sont des autorités indépendantes qui bénéficient d'une totale indépendance, ce sont les premières autorités indépendantes, sans qu'on puisse les désigner comme des AAI.

Dans les années 70, il y a eu un mouvement de création de nouvelles autorités administratives qui se caractérisent par leur indépendance, on a la création d'une catégorie d'autorité d'institutions administratives. Il s'agit de s'inspirer de pays anglo-saxons et de répondre à des aspirations administratives nouvelles. Il s'agit, pour l'Etat, de créer par la loi, des structures administratives intervenant dans des domaines sensibles. C'est cette sensibilité du domaine qui va appeler une structuration particulière et donc une indépendance de ces autorités par rapport à l'Etat. Il ne faut pas que l'Etat dirige lui-même ses structures, mais il s'agit aussi de chercher dans le fonctionnement de ces autorités, des compétences techniques et d'assurer une forme de pluralité des sensibilités. Il y a également la question de la souplesse de fonctionnement : il faut échapper aux pesanteurs de la bureaucratie française. Ces autorités sont capables de prendre des décisions assez rapidement. D'un point de vue politique, ce procédé n'était pas évident car on a eu du mal avec le fait que des administrations ne s'inscrivent pas dans cette hiérarchie administrative traditionnelle. Ce procédé est devenu une

sorte de modèle européen d'administration publique. Toutes les institutions de l'UE se sont inspirées du modèle américain.

Quels sont les domaines d'intervention ?

Le modèle français a été réformé en profondeur par une loi du **20 janvier 2017**, pour harmoniser, mettre à jour la liste de ces autorités. Il s'est agi de mettre en conformité nos AAI avec les standards européens. On s'était rendu compte, à la suite de condamnations par la CEDH et des censures du Conseil constitutionnel, que nos AAI ne présentent pas toutes les garanties d'indépendance ou d'impartialité attendues d'une autorité ayant autant de pouvoir.

Quels sont les domaines dans lesquels ces autorités interviennent ?

Il y a deux grands domaines d'interventions :

- Le domaine de la **régulation** : domaine des activités économiques au sens large

EX : le domaine boursier, le domaine de la concurrence entre les entreprises, le domaine bancaire, le domaine des assurances, le domaine de l'énergie, etc... sont des domaines sensibles au niveau économique qui appelle une intervention de l'Etat qui doit se garder de tout autoritarisme en la matière, car il s'agit aussi de respecter la libre initiative, la liberté du commerce et de l'industrie. Ces domaines nécessitent quand même une intervention de l'Etat pour réguler, mais celui-ci ne doit pas intervenir trop directement.

Dans le domaine de la régulation on des autorités très connues telles que :

- L'autorité des marchés financiers qui a un pouvoir réglementaire qui va déterminer les conditions selon lesquelles, en France, on peut introduire une société en bourse. L'Etat est présent via son gendarme de la bourse pour déterminer, tout en respectant la loi, les conditions dans lesquelles on peut s'introduire en bourse. Cette autorité des marchés financiers dispose de ce pouvoir réglementaire, mais en plus dispose du pouvoir d'infliger de lourdes pénalités aux entreprises et aux dirigeants qui n'auraient pas respecté cette réglementation.

EX : l'autorité de la concurrence est l'autorité qui est chargée de veiller au droit du respect de la concurrence : la FNAC a absorbé les magasins Darty sous la condition de vendre à la concurrence certains magasins FNAC ou Darty. Ainsi, pour éviter qu'il y est un abus, il y a des règles à respecter.

Il y a la régulation des activités dans le domaine de la communication dont une est très importante :

- le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) qui a d'importants pouvoirs sur les autorisations d'émissions. Le CSA est compétent pour contrôler les propos tenus dans des émissions, il opère une classification sur les « pegi 18 », il veille au respect du pluralisme des courants des opinions.
- la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) qui a de forts pouvoirs dans le domaine de la régulation.

Le domaine de **la garantie des droits** :

- Le défenseur des droits est une nouvelle autorité mise en place en **2008** qui est tellement importante qu'elle est consacrée à l'Article 71-1 de la Constitution. C'est une institution dont le représentant est nommé par le Président et qui est chargé d'alerter les pouvoirs publics sur les dysfonctionnements. Il est habilité à intervenir en justice.
- Le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui ont la possibilité d'intervenir dans des locaux de polices, d'hôpitaux, ... pour vérifier que les conditions de la dignité de la personne humaine soient bien respectées. Il y a eu des modifications de la loi suite à des rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
- La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) : suite à l'affaire Kahuzak qui est chargée de recevoir ou de vérifier toutes les déclarations de patrimoines et d'intérêts de certains élus et de nombreux responsables publics.

Un modèle moderne et assez original d'autorité indépendante :

Il y a pas mal de différences entre les diverses autorités mais, il y a tout de même un modèle commun. Les autorités administratives sont créées par des lois. On se rend compte qu'il n'y a pas de modèle prédéterminé. La différence, par exemple, c'est sur le nombre de membres qui composent ces autorités, souvent elles sont collégiales mais, il y en a certaines qui peuvent être incarnées par un seul individu, comme le défenseur des Droits. Une autre différence, c'est notamment la nature et l'étendue des pouvoirs qui leurs sont reconnus. Il y a à ce sujet une très grande diversité, certaines ont un très large pouvoir, disposent d'un pouvoir réglementaire mais qui, d'autre part, elles possèdent aussi un pouvoir de sanction. Elles exercent un pouvoir exécutif mais aussi un pouvoir qu'on pourrait considérer de « quasi juridictionnel », c'est notamment le cas du CSA. Peut alors se poser un problème de séparation des pouvoirs, cette question c'est souvent posé devant la justice constitutionnelle ou européenne. En revanche, d'autres n'ont pas du tout ce type de pouvoir, elles ne sont compétentes que pour formuler des recommandations, elles ne produisent pas du droit mais recommandent, c'est qualifié, par certains, de « droit souple », c'est un simple pouvoir d'avis.

Ces autorités ont tout de même une unité, notamment soudée par les **2 lois du 20 janvier 2017**. Ce sont des lois qui ont mis en place un statut d'ensemble pour ces autorités. On s'était rendu compte qu'il y en avait de nombreuses, et que c'était difficile à qualifier, certaines n'étaient plus nécessaires, d'autres devaient subir une sorte de « toilettage ». Certaines avaient un statut qui n'était pas conforme au standard européen et constitutionnelle à l'organisation. Certains ce sont plaints, d'où les lois de 2017, du manque de pouvoir, ou bien du mélange des genres au sein de ces autorités. Comment une autorité pouvait être à la fois titulaire d'un pouvoir exécutif et juridictionnel, contraire à la séparation des pouvoirs. Certains textes sont venus définir ces autorités et, les ont limités : on est passé de **40 à 25 autorités**. Il y aura certainement d'autres limitations qui vont se dérouler car il y a des fusions, notamment la HADOPI et le CSA. Lorsqu'une autorité est supprimée, c'est parce qu'elle n'a plus d'utilité, sinon, on peut rationaliser leur influence en les fusionnant.

Au sein de ces AAI, il y en a 8 qui disposent de la personnalité juridique. En conséquence, ces 8 qui disposent de la personnalité juridique, sont désormais qualifiées **d'autorités publiques**

indépendantes. Une API est une AAI qui dispose de la personnalité juridique. C'est le même statut mais, elles ont une autonomie renforcée. Parmi ces API il y a le CSA ou la HADOPI, aussi, l'agence française de lutte contre le dopage. Les API seraient une quatrième catégorie des autorités. Les autres n'ont pas la personnalité juridique, c'est le cas de la HAPVP ou le défenseur des droits.

Des règles communes à l'ensemble de ces autorités ont été fixées par les lois de 2017. Il s'agit de définir avec plus de précisions la durée des mandats des membres par exemple. Ces mandats vont désormais de 3 à 6 ans. Les **membres de ces autorités ne sont pas révocables**, le pouvoir politique ne peut pas révoquer les membres de ces AAI car elles sont indépendantes. Ce mandat peut être renouvelé une fois. Nul ne peut être membre de plusieurs autorités. Chacune de ces autorités s'est dotée d'un code de déontologie, un corpus de principe à respecter, notamment déclaration de leur patrimoine, de leur situation éventuelle d'intérêt etc. Chaque autorité rédige, chaque année, un rapport d'activité qui va être remis au Gouvernement et au Parlement. **LIRE CELUI DU CSA ou HAPVP**. Ces lois de 2007 organisent.

Ces AAI posent quand même plusieurs critiques :

- elles sont certes **efficaces mais, manquent à certains égards de légitimité**. Les membres de ces autorités sont nommés par le pouvoir exécutif et donc, ces membres ne sont pas élus. Il y a donc un décalage entre l'étendue des pouvoirs de certaines autorités et leur légitimité a relativisé. C'est plus question de légitimité démocratique.
- Les membres de ces autorités **échappent aux règles du Droit de la fonction publique** et, certains de ces membres ont des **niveaux de rémunérations qui excèdent** très largement celui des plus hauts élus, comme ceux des ministres ou du président de la République. En effet, les fonctions publiques possèdent une limitation de rémunération, que les membres de AAI n'ont pas.
- Le **mélange des genres** : le mélange des pouvoirs qu'on reconnaît à ces dernières. Il y a eu des débats constitutionnels. Certains ont pu penser que, reconnaître un certain pouvoir à ces autorités était une atteinte à l'article 20 de la constitution. Cet article 20 permet de déduire une responsabilité politique du Gouvernement. Ces autorités administratives exercent une partie du pouvoir gouvernemental car, elles disposent du pouvoir réglementaire. Néanmoins, ces autorités ne sont pas responsables devant le Parlement, comme est soumis le Gouvernement. Les AAI disposent d'une parcelle du pouvoir réglementaire sans être responsable. Selon le Conseil constitutionnel, les AAI ont des compétences relativement limitées, il n'y a pas d'objection constitutionnelle fondée sur l'article 20. Le deuxième obstacle était l'article 21 de la constitution qui dispose que, « le premier ministre dirige l'action du Gouvernement ». C'est sur le fondement de cet article 21, qu'un pouvoir réglementaire est reconnu au premier ministre, et au Président de la République. Dans cet article, rien n'est dit sur la possibilité de reconnaître à ces AAI un pouvoir réglementaire, d'où certaines idées que cela contrevenait à la constitution. Selon le Conseil constitutionnel, de nouveau, cela n'est pas contraire car les prérogatives sont limitées. Le dernier article qui a pu poser des problèmes, c'est l'article 16 de la DDHC. Le conseil a été amené à censurer certaines dispositions

législatives en limitant le fonctionnement de certaines autorités. Les autorités qui disposent à la fois du pouvoir réglementaire et d'un pouvoir de sanction, doivent mettre en place une **séparation organique** afin que, ceux qui exercent des pouvoirs réglementaires, ne soient pas les mêmes que ceux qui exercent un pouvoir de sanction. C'est aussi posé un problème sur la gravité de certaines sanctions qui peuvent être prononcées. Ces autorités peuvent sanctionner mais, jusqu'où ? Ces autorités ne peuvent pas prononcer de peines privatives de libertés, ne peuvent pas mettre en prison. Il y a aussi des limites sur les sanctions pécuniaires (sous). Il y avait notamment des sanctions automatiques mais, il faut individualiser la sanction. Le conseil constitutionnel a jugé qu'il fallait individualiser les sanctions. En effet, parfois, elles sont très, voire trop sévères, ceux sont des sanctions punitives.

Ce système des autorités indépendantes peut donc être contesté.

PARTIE 2 : LES RAPPORTS ENTRE ADMINISTRATION ET RELIGION

PARAGRAPHE 1 : INTRODUCTION, DEFINITIONS ET HISTOIRE

A. LES TERMES

Il y a quelques livres qui commencent à parler de droit français de la religion, laïcité, culte etc.

- **Religion** : il n'y a pas de définition juridique de ce qu'est une religion car, l'Etat s'étant séparé des religions, il ne les reconnaît pas et ne peut donc les définir. Cela n'a pas toujours été le cas, durant certaines périodes, certaines religions ont été reconnues, on savait quel culte était des religions, réelles et considérées par l'Etat.

- **Culte** : Il a une définition qui nous est donnée par le droit administratif. D'abord, la notion de culte, renvoie en Droit à la **pratique collective de la religion**, qui est nécessairement prise en compte par le Droit. Les établissements ou édifices cultuels sont soumis à des dispositions juridiques. Cela est normale car toutes les activités humaines sont encadrées. La **loi du 24 août 2021** est une loi qui a principalement un objet cultuel, elle prévoit de nombreuses dispositions en droit administratif, notamment dans le domaine des associations cultuelles. L'idée est de rendre, pour les mouvements religieux, le statut d'associations cultuelles plus attractif. Le statut est plus attractif (notamment financier) mais, permet à l'Etat un plus grand contrôle.

La législation primordiale est la loi du **9 décembre 1905**, la **loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat**. Notre droit ne pouvait pas ne pas tenir compte du phénomène religieux. En France, contrairement à d'autres pays ; même si l'Etat est séparé, il est jacobin, il est centralisateur et a besoins de centraliser, d'encadrer. Le fait religieux est traité comme un fait social. L'Etat, exerce donc un contrôle sur les religions à travers la pratique cultuelle.

- **secte** : Au regard du principe de séparation, il n'y a pas de différence, d'un point de vue juridique, entre une secte et une religion. Néanmoins, on peut établir des distinctions entre secte et culte. Il y a la possibilité en France de créer une secte, cela n'est pas illégal. En

effet, il y a en France, près de 200 « nouveaux mouvements religieux » : des mouvements sectaires. Dans les années 1960, 1970, il y aura une réflexion politique sur ces réseaux sectaires car, des dérives y ont été constatées, la question était de savoir s'il fallait mettre en place une sorte de droit spécifique, applicable aux sectes. Cela n'a pas été fait car, nous sommes dans une société libérale et, il y a une séparation ; cela empêche d'interdire aux gens de croire en quelque chose qui peut nous paraître bizarre, on ne peut pas interdire d'avoir des pratiques, pourvu qu'elles n'aillent pas à l'encontre de la loi. Il y a eu de nombreuses dérives sectaires ; au départ, notamment les privations de soins ou bien ; l'exercice d'une forme d'emprise psychologique, pouvant amener à prendre des décisions qui vont à l'encontre de leur volonté, abus de faiblesse consistant en des escroqueries financières etc. Il y a pu y avoir aussi, notamment toutes infractions sexuelles, sur les jeunes par exemple ou bien ; de l'organisation de suicide collectif comme l'ordre du temple solaire. Au regard de ces dérives, on a essayé de se doter d'une législation qui pourrait être adaptée aux dérives sectaires. Il n'y a pas de législation mais, quelques dispositions comme, la mise en place d'une institution administratives : la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte Contre les Dérives Sectaires, qui est rattachée au ministère de l'intérieur. Elle rend fréquemment des rapports ([LIRE RAPPORT MIVILUDS 2021](#)). Ce rapport essaie d'appréhender le mot secte, sans lui donner une définition. Il y a aussi une liste de mouvements qui sont considérés comme étant sectaires et, ne sont pas interdits mais, appelle une plus grande vigilance.

On a l'analyse des discours de ces mouvements sectaires qui sont souvent des discours anti sociaux ou anti républicains par exemple ils vont remettre en cause certaines politiques menées par l'Etat. Des mouvements sectaires mettent en place leur propre structure éducative, sans contrat avec l'Etat. Aussi, il y a le refus des vaccins pour les enfants par exemple. Également, il y a une coupure des membres de la secte avec leur famille, leur milieu professionnel. Il y a aussi les exigences financières disproportionnées avec des individus sous l'emprise d'une ou plusieurs personnes.

Les premiers mouvements sectaires qui ont été définis comme tels, étaient des mouvements de sectes chrétiennes par exemple. Ils se sont coupés des traditions, au départ, cela était le cas pour les témoins de Jéhova ou de la secte Moon. Avec le temps, d'autres mouvements sectaires n'avaient plus rien à voir avec le christianisme, ils étaient les mouvements « NEW AGE », ils redéfinissaient la spiritualité bouddhiste de manière occidentale. Il y avait aussi des mouvements sur la croyance d'une vie extraterrestre etc. Il y a donc une diversité importante.

Aujourd'hui, on a toujours l'existence de ces mouvements mais, il y a 3 domaines assez propices

VAUDOU

- Notamment celui du développement personnel, avec l'Eglise dite de la scientologie par exemple. On est sur des mouvements qui visent à épanouir les individus. Sont intégrées dans ce mouvement, les mouvements de coaching et le domaine pseudo médicale, des médecines alternatives. Initialement, ils ne sont pas interdits mais, ont pour habitude de dériver.

- Le salafisme qui renvoie à une lecture très conservatrice du courant, ce salafisme est vu, à certains égards comme une dérives sectaires et qui va, à son sens radical, au djihadisme
- Au sein du christianisme évangélique : le néo protestantisme, certains fidèles se dépouillent de leurs bénéfices financiers avec une personne qui se déclare pasteur. Contrairement à l'Eglise catholique qui est très organisée avec un seul chef, le pape.

Du point de vue du Droit administratif, on peut quand même établir une distinction, très relative, entre culte et secte. C'est à travers la reconnaissance du statut d'association cultuelle. Si on souhaite créer une association cultuelle en France, il n'y aura aucune difficulté ; en revanche, si on crée une secte, on monte une nouvelle religion, l'administration peut refuser ce statut. L'administration fiscale a souvent l'habitude de ne pas accorder, de dénier des avantages à ces « nouveaux mouvements religieux ». Cela a été source de beaucoup de contentieux. C'était le cas, des témoins de Jéhova, à la suite d'un très long contentieux. Souvent, les contentieux étaient remportés par l'administration fiscale, les impôts, mais, cela peut changer. On peut donc différencier à travers le statut d'association cultuelle. L'administration contrôle la nature de l'activité des associations et, dès lors qu'elle s'occupe d'autre chose que du culte, l'administration va contester. Les avantages des associations cultuelles, sont que, par exemple, elles ne sont pas soumises à la taxe foncière, il y a également le fait que les revenus sont peu ou pas fiscalisés. C'est pour cela qu'on peut parler de **financement indirect de l'Etat**.

- **sécularisation** : c'est un terme qui peut avoir 2 définitions, une définition juridique et sociologique.

D'un point de vue juridique, il n'est presque plus utilisé, il s'agit d'une **appropriation publique des biens du clergé**. Au lendemain de la Révolution française, il y a eu un mouvement de sécularisation, l'Etat est devenu propriétaire de ces biens et l'a donné aux communes et donc, l'Etat et les communes payent l'entretien et la conservation des biens dont il est le propriétaire, un nouveau financement indirect de l'Etat.

Au niveau sociologique, c'est un mouvement de sortie du religieux. Plus le temps passe, moins les gens sont croyants. Avec le développement des sciences et la démocratisation de l'accès de l'enseignement à la culture mais aussi le consumérisme ; cela fait que les gens sont moins pratiquants. Cela semble vrai, néanmoins, il y a deux tempéraments à emporter. Olivier ROY dit qu'on ne peut pas remettre en cause le processus de sécularisation mais, les gens ne sont pas forcément plus croyants mais il y a un recours à Dieu plus important, c'est le discours, la visibilité. Il y a une deuxième nuance aussi ; cette sécularisation ne touche pas les religions de la même façon : pour des raisons purement conjoncturelles, de la situation actuelle, il y a des religions qui peuvent se traduire comme une plus grande adhésion, notamment au néo protestantisme et l'islam ne sont pas entrés dans ce mouvement de sécularisation. Pour les autres religions, il y a un recul. Lorsqu'on regarde nos grandes religions, elles sont très récentes.

- **laïcité** : la seule définition acceptable est la définition juridique. Le mot laïcité reste tout de même très peu cité dans les textes. Il n'apparaît même pas dans la loi de 1905. Le mot laïcité est néanmoins inscrit dans la constitution mais, il n'est pas défini. On peut donc faire la synthèse des textes juridiques qui abordent ces questions religieuses pour définir ce terme. Le conseil constitutionnel et Conseil d'Etat ont donné des définitions. **La laïcité c'est un principe d'organisation politique et juridique qui se traduit par le principe de la séparation, de la liberté de religion et de la neutralité religieuse.** Néanmoins, l'Etat n'est pas totalement séparé des cultes : il garantit la liberté de religion oui mais, instaure des limites ; il pose la neutralité religieuse, oui mais que pour lui et pas pour les individus.

Il faut en revenir aux origines du terme ; c'est un terme qu'on commence à utiliser qu'à partir du 19^e siècle. Cela est normal car, c'est le siècle qui se traduit par ce mouvement progressif de séparation des églises et de l'Etat. C'est la période où le pouvoir politique va commencer à vouloir des velléités de séparation, tout ça sur le fondement de la pensée des lumières. L'Etat doit se montrer tolérant et libéral en se séparant de l'Eglise. Il est très probable que ce terme ait une double origine : une origine grecque, le « laos » le peuple au sens très large du terme car, les grecs avaient plusieurs façons de définir une collectivité humaine. Le « laos » c'est le peuple dans sa globalité, il y a donc dans le terme de « laïcité », une démarche inclusive. La deuxième origine fait référence au « laicus », c'est celui qui n'exerce pas de fonction religieuse.

B. LES RAPPORTS ENTRE DROIT ET RELIGION DANS D'AUTRES PAYS

Il y a d'autres pays qui se revendiquent comme étant laïques ou qui peuvent utiliser le terme de laïcité, comme la Turquie ou le Mexique. Certains pays n'utilisent pas le terme de laïcité mais, ont mis une place, un régime de séparatrice. Aux US, c'est plutôt le terme de « Secular » qui est utilisé. Ces pays sont laïques mais ne le sont pas. Chaque Etat a son système juridique et, aura une approche différente de ce qu'est la laïcité. Lorsqu'on regarde la législation américaine, les Etats unis sont plus laïques que la France car, aux Etats-Unis, ils sont beaucoup plus rigides, il n'y a pas de financement indirect de l'Eglise comme en France. La séparation est beaucoup plus importante entre l'Etat et les cultes. En France, l'Etat s'est toujours méfié des religions, c'est pour cela qu'il est très vigilant ; en revanche, aux Etats unis, ce sont les religions qui se méfient de l'Etat. Le Dieu au Us est civil, c'est dans le discours pas dans la législation. Il y a d'autres états, comme l'Allemagne, le Royaume uni, qui ne sont pas séparatrices et n'utilisent pas le terme de laïcité. Néanmoins, la liberté de religion est tout de même présente. En Angleterre, la Reine est la représentante de l'Eglise anglicane mais il n'y a aucun problème dans la liberté de religion.

C. L'HISTOIRE FRANCAISE DES RAPPORTS DROIT ET RELIGION

- **1^e Période : des débuts de la France jusqu'à la Révolution. On peut démarrer à la fin de Ve siècle avec le baptême de Clovis jusqu'à la Révolution.** La relation n'est pas apaisée entre l'Etat et le culte, il y a une intrication entre le pouvoir spirituelle et politique. La France

admet le pluralisme juridique et donc, admet le droit de l'église catholique, dit droit canonique, s'applique sur le droit français, notamment dans le droit de la famille. On ne parle pas de théocratie car, le souverain reste le monarque, même s'ils sont souvent chrétiens. Il va y avoir des conflits assez récurrents entre le pouvoir royal et le pouvoir du pape. C'est un conflit de légitimité, divine d'un côté et, de souveraineté de l'autre. Il y a donc des tensions politiques entre la France et Rome, notamment par le droit fiscal et la nomination des membres du clergé. Ces tensions entre Eglise Catholique et France, peuvent expliquer les tensions qu'on a pu subir ces dernières années. C'est souvent par rapport à ce conflit de souveraineté. Il y a une intolérance religieuse durant cette période, les cultes minoritaires comme les juifs puis les protestants. Il y a eu des grosses périodes de tensions, des expulsions, des assassinats (Saint Barthélémy), des emprisonnements qui ne sont que la conséquence de ces tensions envers les religions minoritaires.

- **2^e période : 1789-1801.** C'est la période postrévolutionnaire immédiate. Des textes marquent la volonté de l'Etat de contrôler les cultes et principalement, le culte catholique. L'Etat prend en charge la religion catholique et rémunère les ministres du culte catholique. Cela est effectué pour les contrôler et pour autonomiser l'Eglise catholique française, connu sous le nom de l'Eglise Gallicane. Il y a les premières mesures de « laïcisation », achronique. On met en place un calendrier républicain, on se départit du calendrier gallican. On laïcise l'Etat civil, naissance, décès, mariage etc. qui sera donné aux maires. Il y a un mouvement de tolérance, notamment pour les cultes minoritaires : au lendemain de la religion, on va émanciper les juifs, sera accordée ainsi la citoyenneté française. Il y a aussi une volonté libérale, d'introduction en France de religion civile, une sorte de culte d'Etat. C'est un mouvement qui renvoie à la théosophie, il souhaite de s'émanciper des traditions religieuses pour créer une sorte de culte de lettre suprême, une sorte de Dieu, un grand créateur, qui n'aurait pas d'origine religieuse.

- **3^e période : 1801 à 1905 :** la période dite du Concordat, plus connu sous le nom du « régime des cultes reconnus ». On est sous le Consulat mais, Napoléon veut faire des cultes reconnus, de véritables services publics : l'Etat finance les cultes, rémunère les membres du Clergé. Cette subvention se réalise sur 4 cultes : le catholique, l'Israelite, et aux deux cultes protestants (calviniste, luthérien). Il n'y avait, à l'époque pas d'associations cultuelles mais des **établissements publics du culte**. C'est le pouvoir qui va nommer, in fine, les membres des établissements du culte. Ce système s'applique encore en Alsace-Moselle.

- **4^e période : début de la III^e République à 1905 :** Sous la III^e on va avoir une série de lois qui sont les premières pouvant être considérées comme des lois de laïcisation. La première étant la loi de 1882 sur l'éducation laïque, les enseignants ne sont plus des personnes du clergé et, les cours de religions sont supprimées dans les écoles publiques. Il y a aussi la loi de 1887 sur la liberté des funérailles, on laïcise les funérailles et confie les cimetières publics au maire.

- **5^e période : 1905 à aujourd'hui.** C'est le régime de séparation qui a posé au départ beaucoup de difficulté, notamment concernant l'Eglise catholique. Le culte catholique ne devra plus être financé par l'Etat pour la séparation. Également, l'Eglise catholique va considérer qu'elle ne peut pas fonctionner dans le cadre du système mis en place : les associations cultuelles. L'organisation hiérarchique de l'Eglise chrétienne ne peut fonctionner

dans le système de la loi de 1905. Il y a aussi beaucoup de tension avec l'Eglise catholique dans ce qui concerne l'affectation dans les lieux de cultes. Vu que les établissements appartiennent à l'Etat et aux communes, on se demande à qui le confier. Néanmoins, c'est un régime qui va faire l'objet de nombreuses modifications, la dernière datant du 24 août 2021. Il y aura de nombreuses réflexions sur l'adaptation de la loi de 1905 à une religion peu présente en métropole au moment de son adoption : il s'agit de l'islam. L'islam est une religion très présente sur le territoire métropolitain donc, on se demande comment on peut adapter cette loi à cette nouvelle religion. Au départ, il n'y a pas véritablement de tensions, elles commencent à naître et à être médiatisées vers la fin des années 1980s, notamment 1989 car, la question de la religion revient à l'école. C'est la question des signes religieux à l'école, d'où l'adoption de la loi de mars 2004. La principale difficulté dans la question de l'islam en France, c'est que, par son caractère récent, l'islam n'a pas pu bénéficier des mesures prises dans les décennies antérieures, notamment dans le cadre de son financement. C'est ce qui va poser la question des lieux de cultes musulmans. La question de l'islam a posé un problème au niveau de l'Etat car, l'islam ne disposait pas des mêmes structures représentatives de celles dont ont bénéficiées le protestantisme et le judaïsme. Sarkozy propose de se réunir au Conseil Français de Culte Musulman qui a pour but de mettre en place, un « islam de France ». Il y a, au sein de l'islam, différents courants religieux. Les autorités françaises ont considéré qu'il fallait en privilégier, ce qui ne fut pas le cas des courants conservateurs comme le salafisme. Ce conservatisme religieux n'empêche cependant pas le développement en France, des autres courants républicains compatibles de l'islam. Il existe des statistiques de croyants en France qui ne sont pas immenses : il y a en France, un islam républicain qui est entièrement intégré aux autres religions.

Les courants qui ont été considérés comme peu compatibles avec les principes républicains sont les courants conservateurs, comme le salafisme. Ce dernier n'est pas interdit mais n'est pas adapté au contexte républicain. Par cette compréhension trop conservatrice, il peut amener à un nombre de tensions. Ce conservatisme religieux n'empêche pas le développement en France, majoritairement parlant, de l'épanouissement de courants au sein de l'islam, parfaitement républicains-représentatifs et compatibles. Il y a en France, un islam républicain qui s'intègre très bien malgré certaines tensions, souvent trop médiatisées. « ***Un islam français et possible*** » institut Montaigne.

PARAGRAPHE 2 : LA SEPARATION DES EGLISES ET DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

L'Etat n'est pas totalement séparé des cultes en France. AU regard d'un caractère centralisé de l'Etat, il est relativement présent en ce qui concerne les affaires cultuelles. Le Concordat mis en place en 1801, traduisait la volonté de l'Etat de contrôler les cultes en faisant des services publics. Aujourd'hui, ce contrôle est beaucoup moins direct, il est plus lâche mais, il y a tout de même un **bureau des cultes dans le ministère de l'intérieur**. Le culte est une religion qui va s'organiser, par exemple dans le cadre des associations cultuelles dont l'objet est le culte. Dès lors, une association bénéficie de statut, elle va bénéficier davantage au niveau de la fiscalité. Le statut est avantageux. L'Etat n'est pas totalement séparé des cultes, en effet, le bureau des cultes va délivrer des certificats pour que l'abattage puisse se réaliser par des

sacrificateurs rituels car, en temps normal, cela n'est pas conforme à la législation. Le bureau des cultes va certifier cette méthode pour certains.

1. LE SENS DE CE PRINCIPE DE SEPARATION

La séparation n'est pas totale, il faut la nuancer. La séparation signifie pleins de choses. La séparation implique que **l'Etat** est devenu « **incompétent** » **dans le domaine religieux**. Il n'est pas censé s'intéresser à l'organisation interne des religions. C'est ce qu'il fait de manière générale mais, il reste en discussion pour les amener à s'organiser. L'Etat ne peut nommer les prêtres, les rabbins, les imams d'où l'incompétence néanmoins, il y a tout de même le bureau des cultes (abatage rituel). Il arrive très souvent à l'Etat d'inciter les cultes à s'organiser. Au cours de la période contemporaine, l'Etat a essayé de faire cela avec le culte musulman notamment, au début des années 2000s, sur incitation de l'Etat, certaines associations musulmanes ont mis en place le **Conseil Français de Cultes Musulmans** (CFCM).

Un deuxième exemple est issu de la loi 1905 telle qu'elle a été en partie réformée par la loi du 24 août 2021 ; dans le texte, les religions sont de plus en plus incitées à s'organiser sous la forme d'associations cultuelles. Cela est plus avantageux pour l'association et ses dirigeants mais, c'est également assorti de contraintes, notamment en termes de contrôle. Il faudra par exemple, déposer les comptes de l'association en préfecture pour vérifier d'où vient l'argent ; il s'agit de contrôler que les fonds ne viennent pas trop d'états avec une vision conservatrice.

Qui dit séparation dit absence de financement des cultes (voir 3. : il y a énormément de financement possible qui sont indirects).

Le principe de séparation définit que l'Etat n'est pas compétent pour définir ce qu'est une religion ou une secte. A cet égard, il y a tout de même une approche administrative de la notion de secte. Cette approche est celle qui est proposée par la **MIVILUDS** : **M**ission **I**nterministérielle de **V**igilance et de **L**utte contre les **D**érives **S**ectaires.

A partir de la fin des années 1960s, et l'incompétence de l'Etat en matière de religion, l'Etat s'est interrogé sur l'opportunité d'une législation spécifique aux sectes. Cela ne s'est pas effectué. Dans les années 1960s, il y a, malgré la croyance qui est un peu innée de l'humain, une sécularisation qui a donné lieu au développement aux sectes et aux dérives sectaires. Ces dernières peuvent entraîner l'isolement des individus par rapport à la société, des comportements antisociaux, ces derniers ne sont pas forcément illégaux. Certains comportements peuvent même porter préjudice à soi-même. L'Etat n'a pas agi au premier abord car, la plupart des mouvements sectaires étaient issus de courants religieux traditionnels. Les témoins de Jéhovah étaient connus comme un mouvement sectaire, désormais, ils ne sont plus vu ainsi selon la MIVILUDS. Aujourd'hui, la MIVILUDS considère le salafisme comme étant un courant sectaire. Néanmoins, au regard des abus qui ont été constatés, on a eu une réaction timide des pouvoirs publics. Ces abus ont différentes natures : suicides collectifs, escroquerie économique etc. Dès lors, l'Etat s'est mis à encadrer : il y a quelques articles dans le Code pénal qui concerne ces dérives sectaires. Certaines mesures limitent la publicité, la création d'une infraction spécifique : le **délit d'abus de faiblesse**, qui ne concerne pas que les mouvements sectaires. La législation de droit commun suffit pour

poursuivre ces dérives sectaires (démolition d'un temple avec la loi d'urbanisme, homicide involontaire etc.)

L'incompétence de l'Etat est doublée d'une incompétence des religions dans le domaine étatique. Elles sont incompétentes dans le domaine, néanmoins, les **mouvements religieux** quel qu'ils soient, sont des **corps intermédiaires** : les mouvements religieux ont tout à fait le droit d'agir comme des groupes de pression, de se constituer en partis politiques pour influencer la ou les politiques publiques. Cette incompétence est donc relative.

Parfois, l'Etat peut reconnaître des effets juridiques à des pratiques religieuses. Par exemple, le secret religieux (secret des confessions) est considéré, en jurisprudence, comme un secret professionnel. Également, le droit musulman ne reconnaît pas l'adoption, c'est une procédure de recueil légale d'un enfant : la Kafalla. La jurisprudence admet de leur reconnaître des effets juridiques.

2. LES EXCEPTIONS TERRITORIALES AU PRINCIPE DE SEPARATION

Il s'agit de partie du territoire français qui n'applique pas le principe de séparation. Il y a principalement 2 zones : la première se situe en métropole et la seconde en outre-mer.

- **L'Alsace-Moselle** en métropole : dans ces territoires, le Concordat s'applique encore. On est en France mais dans le système des cultes reconnus avec des pasteurs, des prêtres, des rabbins payés par l'Etat. Cela est lié à l'histoire de cette zone, qui n'était pas souveraineté française au moment de l'adoption de la loi de 1905. En 1919, on a donc adopté un texte qui permettait de maintenir temporairement le Concordat. Le temporaire est devenu pérenne. En 2013, il y a eu une QPC sur la conformité à la Constitution de ce régime un peu spécifique. Elle a été validée, le Conseil constitutionnel dit que c'est conforme à la Constitution. Le régime est donc toujours applicable. Les habitants seraient plutôt favorables à sa suppression.

Néanmoins, il y a des problèmes notamment avec l'islam au niveau juridique car, la religion n'est pas reconnue du fait que lors de Concordat, il n'existait pas en France. Il y a donc une situation d'inégalité. Il y a eu des textes qui accordaient les subventions des imams et de la religion musulmane mais, de nombreuses polémiques persistent.

- En **outre-mer** : au départ, la loi de 1905 ne s'appliquait pas, aujourd'hui, elle s'applique à la Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique (article 73 : départements d'Outre-mer). Néanmoins, dans les collectivités d'outre-mer, mais aussi en **Guyane**, il y a un régime spécifique. Par exemple, en Guyane, uniquement le clergé catholique est payé par les fonds publics du département, c'est également le cas en Polynésie etc. De plus, Mayotte est devenu un département d'outre-mer en 2011 mais, jusqu'en 2011, il y avait qu'un culte reconnu : l'islam et les imams étaient payés par l'Etat. Jusqu'en 2011, les Mahorrés avaient la possibilité de demander qu'on leur applique la Charria dans le domaine de leur statut personnel. Désormais, les Mahorrés ont des **cadis** qui sont des juges musulmans, religieux, qui sont rémunérés par l'Etat pour jouer le rôle de médiateurs sociaux. Il est membre d'une administration.

3. LES FINANCEMENTS PUBLICS INDIRECTS DES CULTES

Le principe de séparation implique que l'Etat ne subventionne ni ne salarie aucun culte, dans l'article 2 de la loi de 1905. Il y a énormément d'exceptions à cette règle. Ces exceptions s'expliquent de 2 façons :

- Comme **l'Etat doit garantir le libre exercice des cultes**, il va nécessairement être amené à financer.
- Historiquement, l'Etat est propriétaire. Les personnes publiques sont propriétaires d'édifices cultuelles (90% des édifices catholiques). En tant que propriétaire, il se doit de financer l'entretien et la conservation des édifices cultuels.

Il y a des financements directs, semi-directs et indirects. Il y a beaucoup plus de financements indirects.

- **Les financements directs :**

Ceux sont les services **d'aumônerie** ; l'Etat rémunère les aumôniers du culte pour que ces derniers aillent se rendre dans les lieux clos pour assister les croyants dans leur pratique religieuse. C'est le cas pour les hôpitaux et pour les prisons.

- **Les financements semi-directs :**

- L'Etat finance par exemple les **émissions religieuses** (le jour du seigneur sur la 2 par exemple). Il les finance pour promouvoir le pluralisme religieux. Ces émissions utilisent des dépenses publiques.
- **L'entretien et la conservation des édifices cultuels publics.** Depuis le régime de Vichy, les personnes publiques peuvent financer les travaux de réparation des lieux de culte, quel qu'ils soient, même s'ils sont privés.

- **Les financements indirects :**

- Le **statut des associations cultuelles**. Via ce statut, il y a des **avantages fiscaux**, il n'y a pas de taxes foncières. Depuis la loi de 2021, les associations peuvent se financer via la perception de revenus locatifs (reçoivent des immeubles et peuvent les louer).
- Dans le domaine de la **construction immobilière**, il y a 2 techniques qui facilitent la construction d'édifices religieux. Le premier exemple est la **garantie d'emprunts** : c'est une forme de caution qui va être donnée par l'Etat ou par une commune lors de la demande d'un prêt. Il y a aussi la technique de **bail emphytéotique**, c'est un bail de longue durée par lequel une personne publique va louer un terrain pour une durée pouvant aller jusqu'à 99 ans, moyennant un loyer symbolique d'1€ par an. Ce financement est indirect car il s'agit de mettre

en mesure les associations cultuelles d'avoir un terrain sans payer. Le bien construit entre dans le patrimoine de la personne publique, il n'appartient pas à l'association.

- Le troisième exemple est issu de **5 décisions du 19 juillet 2011 par le Conseil d'Etat**. On peut désormais attribuer des **subventions publiques** à des **associations cultuelles** pour des **questions ne relevant pas directement du culte** mais en lien avec ce dernier.

1. Par exemple, la question était de savoir si une commune pouvait subventionner la construction dans une basilique d'un ascenseur. L'ascenseur n'est pas le culte mais, c'est dans une basilique donc cela a été accepté. Ce n'est pas la totalité qui a été subventionné mais une partie car, l'ascenseur peut contribuer au rayonnement touristique et permet également à des personnes handicapées d'avoir un accès plus facile.

2. Peut-on subventionner la réparation de l'orgue d'une église ? Elle sert à faire de la musique mais également à célébrer. Le Conseil d'Etat dit qu'on peut subventionner mais pas dans la totalité, l'intérêt est alors les cours de chant.

La légalité de ces **subventions repose sur l'existence d'un intérêt public local**.

PARAGRAPHE 3 : LA LIBERTE DE RELIGION

A. LA SIGNIFICATION

L'Etat étant incompétent dans le domaine religieux, il ne définit pas ce qu'est la religion. Qu'est ce qu'on a le droit de faire en matière de liberté religieuse, aussi irrationnelle que la pratique puisse être. La liberté de religion consiste à **faire tout ce que l'on veut dès lors que cette pratique n'est pas interdite par la loi**. L'Etat va prendre position dans certaines pratiques qu'il considère comme inadmissible. Des textes précis viennent interdire certaines pratiques, en tant que pratiques qui sont contraires à l'ordre public.

Au niveau de la liberté de religion, il y a plusieurs aspects :

- d'abord un aspect qui **renvoie à la distinction interne/externe**. La liberté **interne** est la question de la **liberté de conscience religieuse**. Cette liberté semble absolue : comment la législation peut limiter la liberté de croire ? Néanmoins, il y a des limites posées : un maire ne peut pas, au nom de ses convictions religieuses, refuser de célébrer un mariage entre des personnes de même sexe. Également, l'obligation pour certaines personnes de prêter serment, c'est le cas si l'on devient magistrat, avocat, policier : c'est un **serment juratoire**. Dans certains cas, certaines personnes n'ont pas souhaité prêter serment car, elle considérait cela comme contraire à leur liberté de conscience (contre les convictions religieuses). La **Cour de cassation du 7 juillet 2021**, dit qu'on peut dispenser un individu de ce serment juratoire, en lui proposant une autre formule solennelle. La liberté **externe est la manifestation**.

- la liberté peut s'effectuer de manière individuelle ou collective. Le droit français vient organiser cette liberté collective notamment avec la création d'une association cultuelle, la possibilité de créer une structure juridique.

B. LES PRATIQUES RELIGIEUSES TOLEREES

Sur le fondement de la liberté de religion, l'Etat tolère voire encadre certaines pratiques qui, en principe, sont illégales, dès lors qu'elles ont un fondement religieux.

- **L'abattage rituel** notamment pour les cultes musulmans et juifs. Cette méthode fait l'objet d'une législation spécifique, elle permet de dispenser de l'obligation d'étourdissement préalable des animaux. De plus en plus de pays sont en train d'interdire l'abattage rituel : la Grèce, l'Allemagne, le Danemark. Le 17 décembre 2020, la Cour de justice de l'UE a eu comme question si cela ne portait pas atteinte à la liberté religieuse. Elle a répondu que non, c'est une limitation mais pas une atteinte. La justification pour la Cour Européenne est l'ordre public, notamment la souffrance de l'animal.

- La question de la **circoncision** : la circoncision n'est pas interdite, en revanche, elle est contraire à priori, à l'article 16-3 du code civil. Néanmoins, la circoncision cultuelle est tout à fait possible. Si la **circoncision n'est pas punie**, il en va différemment de l'**excision** qui est considérée comme constituant un **crime**. C'est une atteinte à l'intégrité corporelle de la femme notamment avec l'ablation du clitoris.

- Les **funérailles et de l'inhumation** : la loi de 1887 introduit la liberté des funérailles et, c'est sur le fondement de cette loi, qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des funérailles civiles : sans fondation religieuse. Cela signifie qu'on peut être incinéré. Malgré le caractère neutre des cimetières publics, les croyants peuvent être enterrés au sein de carrés confessionnels (carré protestant, musulmans, juifs etc.). On peut également les enterrer selon une direction précise : tête en direction de la Mecque etc. Néanmoins, certains croyants souhaitent ne pas être mis dans un cercueil, cela n'est pas accepté.

- les **entreprises de tendances** : en droit du travail, il y a une législation qui interdit les discriminations etc. Un recruteur n'a pas le droit de demander les convictions religieuses. Cela n'est pas le cas des entreprises de tendance. Ces dernières peuvent être des associations, des partis politiques, des syndicats etc. dont l'objet est l'exercice d'un culte ou la promotion d'un culte. C'est le cas des écoles privées concessionnelles par exemple, un restaurant casher ou halal, un libraire de livre religieux. Ces entreprises de tendances, peuvent, à certaines conditions, discriminer leur salarié et/ou, exiger d'eux, une obligation de loyauté renforcée. Cela peut se comprendre au regard de l'objet de l'entreprise.

C. LES LIMITES A LA LIBERTE DE RELIGION

Il y a 2 séries de limites : des limites générales et des limites spéciales.

- Les **limites générales** : elles sont contenues dans la loi et s'appliquent donc sur l'ensemble du territoire et, tout le temps. Elles sont fondées, soit sur la protection de l'ordre public, soit sur le respect des droits et libertés d'autrui. Cela fait parti des choix politiques qui ont été fait dans notre histoire, notamment la **loi du 11 octobre 2010**, qui interdit la **dissimulation du visage dans l'espace public**. Cette loi a été validée par le Conseil Constitutionnel, par la Cour Européenne des droits de l'Homme et, d'autres pays se sont

inscrits dans le sillage de cette limitation dont la France était la première à instaurer. Il y a aussi le respect des droits et libertés d'autrui, c'est le cas de la législation réprimant le délit d'abus de faiblesse. Récemment, avec la loi du 24 août 2021, certaines dispositions interdisent certaines pratiques, à peu près religieuses, les médecins n'ont plus le droit d'effectuer des certificats de virginité, qui peuvent être demandés pour les convictions religieuses.

- Les **limitations spéciales** : elles sont souvent le fait d'autorité locale notamment le préfet et le maire. Ils peuvent limiter la liberté de religion lorsqu'elle forme un trouble à l'ordre public. C'est le cas, de fermeture de lieux de cultes dans lesquels s'étaient déroulés des manifestations politiques par exemple. Certains lieux ont été fermés par exemple dans les chambres qui soutiennent le terrorisme. Les maires peuvent également limiter les sonneries de cloches lorsqu'elles causent des troubles à la tranquillité publique. Néanmoins, la presque totalité des arrêtés municipaux interdisant le burkini, ont été annulés car cela ne constituait pas un trouble à l'ordre public.

D. LA LIBERTÉ DE RELIGION DANS LES RAPPORTS ENTRE PARTICULIERS

La question est de savoir comment garantir la liberté de religion entre individus. Chacun d'entre nous n'a aucune obligation, nous ne sommes pas tenus de garantir la liberté de religion de nos semblables.

- 1^{er} exemple issu du droit des biens : l'affaire dite du **digicode** du **18 décembre 2002**. C'est une affaire ancienne qui a été confirmée à plusieurs reprises. Une famille juive pratiquante qui louait un appartement avait demandé au propriétaire de faire installer à l'entrée de l'immeuble, un système de clef. Ils ont demandé car, cela s'effectuait avec un digicode, un mécanisme moderne, néanmoins, étant pratiquant, il ne pouvait pas rentrer dans leur immeuble le samedi car ils n'utilisent pas l'électricité. Le propriétaire a refusé et sont donc allés en Cours de Cassation car cela était contraire à la liberté de religion, néanmoins, cette dernière a dit que cela n'était pas contraire, on ne peut obliger des particuliers.

- 2^e exemple : L'employeur n'est jamais tenu de garantir la liberté de religion de ses salariés. On peut parler de l'**affaire de la boucherie**. Un salarié étant devenu musulman, il a demandé à ne plus manipuler la viande de porc, il a été licencié mais cela est acceptée par la Cour de cassation.

- 3^e exemple concernant la **liberté d'expression** : On a la possibilité d'avoir des propos choquants qui heurtent la sensibilité religieuse. La liberté d'expression permet de heurter les convictions religieuses. Il y a 3 limites : la diffamation, l'injure et l'incitation à la haine, ici religieuse. La limite est de ne pas s'en prendre à des personnes en particulier ou à des groupes de personnes en les injuriant ou en leur prétendant des pratiques diffamatoires. On peut s'en prendre à la religion mais pas aux pratiquants.

Examen QCM 40 questions : 1 réponse,

Réponse fausse - 0,25 ; si juste 0,5 ; si pas répondu 0.

Laquelle de ces limites à la liberté d'expression n'est pas pénalisée :

- A. L'injure
- B. Diffamation
- C. Incitation à la haine religieuse
- D. La moquerie d'une croyance